

人进一步确认；进行实地勘验和占有状况确认等。对任何可能引发合理怀疑的材料，如文书内容前后矛盾、格式

不统一、来源不明等，商业银行负有主动核查义务。而对于其他非银行类专业金融机构，如小额贷款公司、融资担保公司、典当行等，其虽非《中华人民共和国商业银行法》的直接规制对象，但由于其业务性质与风险控制、防范能力等与商业银行相似，且多受地方金融监督管理局或中国人民银行授权监管，其业务规范中亦通常包含尽职调查、实质审查、贷款文件核验等基本要求，因此，如上述机构在放贷或设立抵押权过程中具备相当的专业与风险控制能力，并体现系统性运作模式时，可根据具体情况比照商业银行注意义务的审查标准判定上述机构是否存在重大过失。

本案中，某银行虽然审查了案涉房屋的登记证书，通过公证机构办理了借款和抵押手续，并就案涉房屋进行了入户调查，但其在审查抵押人李某对于案涉房屋的处分权利的重要依据，即回某某和李某之间的民事调解书事宜上没有尽到严格审查义务。在调解书存在字体字号不一致、序号不连贯、内容前后矛盾等明显瑕疵，足以引起合理怀疑的情况下，某银行作为办理抵押贷款的专业机构，没有及时向法院或者调解书的另一方当事人就相关情况进行核实，没有尽到严格审查义务，对于抵押权登记存在重大过失，不应认定其为善意。

编写人：北京市海淀区人民法院 蒙向东
张帅

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终7341号民事判决书

2. 案由：抵押权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):方甲、方乙

被告(上诉人):某信托有限公司(以下简称某信托公司)、北京某资产管理有限公司(以下简称某资产公司)、杭州某资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称某资产企业)

第三人(上诉人):某小额贷款有限公司(以下简称某小额贷公司)、某科技投资有限公司(以下简称某投资公司)

【基本案情】

方甲、方乙、方丙系兄弟姐妹关系。

2017年11月21日,方丙通过虚假受赠的方式取得原由其父母所有的位于北京市西城区的案涉房屋的产权,并办理了产权登记。12月1日,方丙以该房屋办理抵押,抵押权人为某典当公司,抵押金额为440万元,该抵押权于2018年2月2日解除;方丙又以该房屋于2018年2月12日办理抵押,抵押权人为案外人陈某,金额为442.2万元,该抵押权于2018年3月22日解除。

2018年3月21日,方丙与某信托公司签订《抵押保证借款合同》,约定:方丙从某信托公司贷款465万元,用于日常经营及消费;贷款期限自2018年3月21日至9月21日;抵押物为案涉房屋。同日,方丙与某信托公司共同向北京市某公证处申请赋予该《抵押保证借款合同》强制执行效力;3月26日,该公证处出具了公证书。

2018年3月23日,某信托公司向方丙发放贷款465万元。3月26日,方丙与某信托公司就上述房屋办理了抵押登记手续。

后,方甲、方乙以合同纠纷诉讼请求确认父母与方丙的赠与合同不成立,并通过行政诉讼撤销了方丙取得的案涉房屋不动产权证。

现,方甲、方乙诉至法院,请求确认方丙将案涉房屋抵押给某信托公司的抵押行为无效,并要求某信托公司等配合方甲、方乙解除案涉房屋的抵押权登记手续。

【案件焦点】

某信托公司是否符合善意取得抵押权的构成要件。

【法院裁判要旨】

北京市西城区人民法院经审理认为：在另案生效民事判决“确认将案涉房屋赠与方丙的赠与合同不成立”生效行政判决也判决“撤销方丙的案涉房屋《不动产权证书》”的情况下，方丙于2018年3月26日将该房屋抵押给某信托公司的行为构成无权处分。故，本案审查的核心在于某信托公司是否对该抵押权构成善意取得。

从放贷过程来看，2017年11月22日，案涉房屋所有权登记至方丙名下，2017年12月1日，方丙便第一次使用该房屋进行抵押，抵押金额为440万元，之后在短短的4个月内，方丙先后利用该房屋进行了三次抵押。作为专业放贷机构，此种情况理应引起某信托公司的高度注意。然而，某信托公司进行入户调查的时间为2018年3月1日，此时案涉房屋上案外人陈某的抵押权尚未解除。在放贷审查中，某信托公司将部分审查工作交由在北京区域内没有经营贷款业务资格的某小额贷公司进行。对于此笔放贷业务，有关监督管理部门也认定存在诸多瑕疵，包括“某信托公司未对其委托贷款服务机构尽到足够的监督义务”“某信托公司未对贷款服务机构借款用途调查工作进行有效监督”“未见委托贷款服务机构收集方丙工作收入来源相关材料”“某信托公司放款时间早于《公证书》和《不动产登记证明》出具时间，存在业务办理瑕疵”。最后，通过某信托公司等向法庭提供的入户调查照片可以明显看出案涉房屋存在多人共同居住使用的表征，而某信托公司却未对此作进一步的了解与调查。由此可见，某信托公司的工作存在诸多瑕疵及不合常理之处。在此情况下，某信托公司等主张对该笔抵押权构成善意取得，难以支持。

北京市西城区人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

某信托公司与方丙就案涉房屋设立抵押权的行为无效，某信托公司、某资

产公司、某资产企业于本判决生效之日起三十日内配合方甲、方乙办理该抵押权注销登记手续。

某信托公司、某资产公司、某资产企业及某小额贷款公司、某投资公司不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：某信托公司作为专业的放贷公司，应当预见真实物权状态可能与公示状态存在差别，对抵押物权属登记情况可能存在的风险亦具备高于一般社会公众的甄别能力。虽然案涉房屋在办理抵押时登记在方丙名下，但某信托公司的举证不足以证明其在签订抵押合同时尽到了其作为专业机构的审慎注意义务，且河南银保监局某答复意见书亦表明某信托公司在此过程中存在诸多违反行业管理规范的行为，故一审法院结合放贷过程、人户调查等情况认定某信托公司不符合抵押权善意取得的法定条件，并无不当，依法予以确认。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

金融机构在抵押贷款业务中取得抵押权，往往系其贷款资金安全的最大保障，而房屋作为最常见的抵押物在融资中广泛使用。然而，在司法实践中，确实存在一些情形可能会影响到已经登记的抵押权效力，使得原本稳定的金融交易面临风险。此种情况下，金融机构是否可以依据善意取得制度享有抵押权便是焦点问题。

一、善意取得及不动产抵押权善意取得的构成要件

所谓善意取得，是指行为人无权处分他人的财产，受让人取得该财产时出于善意，则受让人依法取得标的物的所有权或其他物权的法律制度。善意取得作为民事法律中的一项重要制度，因善意受让人取得物权系基于法律的规定，故系物权取得的一种特别方式。

《中华人民共和国民法典》第三百一十一条沿袭了原《中华人民共和国物权法》关于善意取得制度的系统规定，其中，第三百一十一条第一款规定了善

意取得的适用前提和构成要件；第二款规定了原所有权人的救济途径；第三款则规定了其他物权的善意取得参照适用前两款规定。另，《中华人民共和国民法典》第一百一十四条规定：“民事主体依法享有物权。物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。”抵押权作为担保物权之一，属于物权的一种，存续于抵押财产之上，具有对世效力。因此，结合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第三十七条第一款“当事人以所有权、使用权不明或者有争议的财产抵押，经审查构成无权处分的，人民法院应当按照民法典第三百一十一条的规定处理”，以及《中华人民共和国民法典》第三百一十一条第三款“当事人善意取得其他物权的，参照前两款规定”可以确定，法律及司法解释已明确无权处分下的抵押权参照适用善意取得制度。

考虑到不动产抵押过程中不存在抵押权人支付对价的问题，故结合相关司法实践，认定不动产抵押权善意取得的构成要件有三：（1）金融机构是善意抵押权人。由于“善意”涉及主观因素，在司法实践中，关于“善意”的认定比较复杂，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》第十四条规定了受让人善意的认定标准：受让人不知且非因重大过失而不知转让人无权处分；并明确对于善意的认定采取推定方式，即首先推定受让人为善意，再由真实权利人或利害关系人就受让人非善意进行举证证明，若真实权利人或利害关系人无法证明受让人不构成善意的，则认定受让人为善意。

（2）存在真实的担保债权。基于抵押权作为担保物权的特殊性质，抵押合同从属于借款合同等主合同，抵押权从属于主债权，由

此，抵押权人已经履行完毕主合同义务，即存在真实的担保债权系不动产抵押权善意取得的构成要件之一。

(3) 已完成不动产抵押权登记。由于我国实行“不动产登记生效”主义，故抵押权人只有依照法律规定完成了抵押权登记，才受到登记公信力的保护，后续方能适用不动产抵押权的善意取得。

二、善意取得之“善意”的认定标准

司法实践中，认定无权处分情形下抵押权人取得抵押权是否为善意，主要

从以下两点展开：

1. 抵押权人不知抵押人无处分权。此为消极事实，一般情况下抵押权人无须也无法举证证明。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》第十五条的规定，真实权利人可通过举证证明以下两类事实，来证明抵押权人知道抵押人无处分权，反推抵押权人并非善意。（1）不动产登记簿上载有对不动产物权处分的限制事项，因不动产登记簿具有公示效力及权利推定效力，那么其上记载的内容就应推定为抵押权人知晓。（2）真实权利人或利害关系人既可以举证证明抵押权人对于登记簿上记载的权利主体错误是知晓的，如抵押权人事前知晓登记权利人和真实权利人之间的关系或是知晓存在登记错误，也可以举证证明抵押权人事先知道他人已经依法取得不动产物权，如依据法院、仲裁机构的法律文书取得物权的情形。

2. 抵押权人对不知道抵押人无处分权无重大过失。该项认定要结合交易主体、背景和过程等事实作具体分析，判断原则是采取客观评判标准，即一般理性人在通常情况下尽到注意义务即可得知抵押人无处分权，而抵押权人却因消极注意而不知晓，即可认定抵押权人存在重大过失。但因金融机构系专业放贷机构，其应尽到区别于一般自然人的更高程度的审慎注意义务，故其在设立抵押权时，其是否尽到审查注意义务便是认定其是否构成“善意”的重要考量标准。

三、善意取得之“善意”审查认定的重点、要点

司法实践中，人民法院往往会综合考虑多个因素，并重点对相关证据进行严格审查，如抵押权的设立过程、抵押物的价值、贷款用途、合同履行情况、金融机构的资质和经验等。

1. 房屋实地勘察。人民法院在审查“善意”的过程中，一个重要的关注点是金融机构在发放贷款前是否对房屋进行了实地勘察，以及是否具备相关佐证材料，如入户视频和照片等。实地勘察能够深入了解房屋的真实状况，包括权属情况、房屋内部结构、装修情况、实际居住情况等。实地入户勘察的结果将直接影响金融机构的决策，因此系人民法院审查的重点。

2. 房屋评估报告。实践中，对房屋评估报告是否为发放贷款前的必需材料，并没有统一的要求，因此人民法院在审理案件过程中，将综合具体情况进行判断。审查抵押物评估报告的主要目的是获取关于房屋真实状况的准确信息，因此，报告内容的真实性、准确性和完整性至关重要。除报告内容与实际房屋情况是否相符外，人民法院重点关注的就是出具房屋评估报告时委托人的身份。如果是金融机构委托第三方进行评估出具的评估报告，在案件审理中法院会倾向于认定该报告系金融机构履行审慎义务的措施，从而有助于对金融机构善意的认定；相反，如果是债务人自行委托后出具的报告，因其客观性无法保证，因此难以作为金融机构善意的有力凭证。

3. 房屋登记情况。我国司法实践中，物权登记的公示公信效力在法律意义上的地位举足轻重。房屋所有权证书、他项权证等文件是判断物权权属的重要依据，但法院在审理相关案件时，一般不会作为唯一依据，在审查时会结合金融机构是否尽到审查义务、贷款的合法合规性等因素综合认定。

4. 善意认定的时点。在审查善意的时点上，人民法院主要关注的是贷款发放时和办理抵押登记时这两个时点。这两个时点系判断金融机构能否适用善意取得的重要依据。假设金融机构在贷款发放或办理抵押登记前就已经知道抵押人的无权处分行为，那么就不能被认定为是善意的。相反，即可被认定为是善意的。在实际操作中，判断金融机构是否善意需要结合具体情况综合认定。一般来说，如果金融机构在贷款发放或办理抵押登记时尽到了合理的注意审查义务，但仍然无法发现抵押人的

无权处分行为，且由于不可归结金融机构的原因，那么就可以被认定为是善意的。相反，即不能被认定为是善意的。

就本案而言，某信托公司进行入户调查的时间为2018年3月1日，此时案涉房屋上原有的抵押权尚未解除；在放贷审查中，某信托公司将部分审查工作交由在北京区域内没有经营贷款业务资格的某小额贷公司进行；另，入户调查照片显示案涉房屋存在多人共同居住使用的表征，而某信托公司却未对此作进一步的了解与调查，由此可见，该公司并未尽到其应尽的审查注意义务。

为防范不动产抵押履职不到位所引发的操作风险，金融机构应进一步加强对抵押不动产取得方式及相关使用情况等的调查，以避免无权处分，或在无权处分的情形下符合不动产抵押权善意取得的构成要件，从而将资金安全风险降至最低。

编写人：北京市西城区人民法院 石博

59

抵押权人对添附物拍卖款优先受偿范围的认定

——刘某某诉淄博某商业银行股份有限公司、淄博某公司物权保护案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省淄博市中级人民法院(2023)鲁03民终1566号民事判决书

2. 案由：物权保护纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):刘某某

被告(上诉人):淄博某商业银行股份有限公司(以下简称某银行)、淄博某公司(以下简称某公司)

【基本案情】

刘某某与某公司于2015年、2017年、2018年签订多份租赁合同，承租某公司的厂房设备等资产，刘某某在租赁期间投入资金购置机器设备，并对租赁资产进行了更换、修建、扩建等。2016年12月23日，某公司向某银行借款8450000元，借款期限为一年，某公司以其案涉租赁标的在内的生产线、设备等资产作为抵押物提供担保，同日签订抵押合同并办理了抵押物登记，注明评

估值为31015300元。后，某公司与某银行的借款合同纠纷一案进入执行程序，在执行过程中将上述刘某某投入的资产一并拍卖，拍卖成交价款为7005260.38元。为此，刘某某提起执行异议之诉，法院经审理认定，“刘某某对因添附行为导致租赁物增值部分有权另行要求折价补偿”，驳回了刘某某的诉讼请求。随后，刘某某申请对其租赁的某公司添附设备的价值进行补充评估，经评估该资产评估价值为1654276.70元。刘某某遂提起本案之诉，要求某银行、某公司支付添附物补偿及增值款3600000元。

【案件焦点】

承租人的添附行为使抵押物增值的，如何认定抵押权人对添附物拍卖款优先受偿的范围。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市淄川区人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第三百二十二条规定：“因加工、附合、混合而产生的物的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律规定；法律没有规定的，按照充分发挥物的效用以及保护无过错当事人的原则确定。因一方当事人的过错或者确定物的归属造成另一方当事人损害的，应当给予赔偿或者补偿。”本案中，刘某某与某公司于2018年3月10日签订的协议中约定：原租赁合同中因设备改造所投资购置的机器设备全部由刘某某实际出资并归刘某某所有，即抵押物所有权人某公司与刘某某明确约定了刘某某添附的财产属于刘某某，刘某某租赁部分的资产与其添附部分的资产形成了某公司与刘某某共有的状态。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第六十二条规定：“……第三人与抵押物所有人为附合物、混合物或者加工物的共有人的，抵押权的效力及于抵押人对共有物享有的份额。”虽然刘某某的添附行为发生在租赁资产的抵押权设立之后，但是刘某某对其租赁资产进行更换、修建、扩建的目的是维持和改善租赁设备的正常生产使用，且实质上使得租赁资产产生了增值，故刘某某享有因其添附行为对共有物享有的份额要求补偿的权利。案

涉抵押物虽不可分割，但抵押物因添附产生的份额及增值能够明确，某银行作为案涉资产的抵押权人，对于拍卖所得价款并非享有全部的优先受偿权。在添附物归抵押人某公司与刘某某共有的情形下，抵押权的效力及于抵押人对添附物的应有部分。某银行在某公司所抵押财产价值以及增值部分的范围内享有优先受偿权，其优先受偿的范围不包括刘某某添附的财产价值以及增值的部分。某公司所属建筑物及机器设备拍卖时的原资产鉴定价值为3643339.24元，拍卖成交价为7005260.38元，资产增值率为192.27%，刘某某所添附的资产评估价值为1654276.70元，根据上述比例计算，刘某某应得的拍卖价款应为3180677.84元。某银行在剩余拍卖价款范围内优先受偿。

山东省淄博市淄川区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第三百二十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条第二款、第六十七条第一款、第一百三十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二条、第三条规定，判决如下：

一、本院于2022年4月7日某公司所属房屋建筑物及机器设备一宗的拍卖款中的3180677.84元归刘某某所有；

二、某公司于本判决生效之日起十日内支付给刘某某诉讼保全责任保险费5400元、鉴定费5000元，合计10400元；

三、驳回刘某某的其他诉讼请求。

某银行、某公司不服一审判决，提起上诉。

山东省淄博市中级人民法院经审理认为：根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第六十二条规定，在抵押权依法设立后，抵押人与第三人因添附成为添附物共有人的情况下，抵押权的效力及于抵押人对添附物的应有部分。本案中，案涉添附物系刘某某与某公司共有，某银行抵押权的效力仅及于抵押人对添附物的应有部分，并不及于刘某某对添附物的应有部分。因某银行、某公司均未提供证据证明案涉添附物拍卖溢价与刘某某的添附不具有关联性，故刘某某对添附物的应有部分应包括其添附财产

本身的价值以及溢价部分，一审对此计算正确，该部分拍卖价款应归属于刘某某所有。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第四十一条第二款规定，抵押权依法设立后，抵押财产被添附，抵押人对添附物享有所有权，抵押权人主张抵押权的效力及于添附物的，人民法院应予支持，但是添附导致抵押财产价值增加的，抵押权的效力不及于增加的价值部分。根据上述规定，即便在添附物归抵押人所有时，抵押权的效力及于添附物，但在添附导致抵押财产价值增加的情况下，抵押权人的效力亦不及于增加的价值部分，以保障因添附而丧失权利的当事人的补偿请求权。故，某银行关于其作为抵押权人受偿全部拍卖款的理由不能成立。

山东省淄博市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十六条、第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要涉及抵押权人对于添附物拍卖款优先受偿范围的认定问题。

添附是几种物上行为的统称，在担保领域，抵押物上存在添附是较为常见的实务状态。《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）施行前，已有司法解释对于添附物上抵押权的效力范围进行了一定明确，原《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第六十二条规定：“抵押物因附合、混合或者加工使抵押物的所有权为第三人所有的，抵押权的效力及于补偿金；抵押物所有人为附合物、混合物或者加工物的所有人的，抵押权的效力及于附合物、混合物或者加工物；第三人与抵押物所有人为附合物、混合物或者加工物的共有人的，抵押权的效力及于抵押人对共有物享有的份额。”《民法典》施行后，司法解释对于抵押权效力范围作出了更进一步的规定，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度

的解释》第四十一条第二款规定：“抵押权依法设立后，抵押财产被添附，抵押人对添附物享有所有权；抵押权人主张抵押权的效力及于添附物的，人民法院应予支持，但是添附导致抵押财产价值增加的，抵押权的效力不及于增加的价值部

分。”该条规定是对抵押权人在添附物上优先受偿范围作出的限制，当抵押物发生添附时，抵押权的效力范围并不及于添附物的全部价值。

存在添附的抵押财产因抵押人无法清偿债务被拍卖后，所得的拍卖价款应如何分配，拍卖款能否优先受偿于抵押权人，在实践处理中应从以下两个方面进行判断：（1）抵押物添附对抵押物范围的扩张。《民法典》第三百二十二条从原则上对添附物权属进行了规定，在尊重意思自治的基础上，注重保护物的经济效用，即有约从约，无约则高价值一方取得添附物。抵押物添附归属确定后会产生两种状态：一是原抵押物与添附物整体由抵押人与第三人形成共有；二是抵押人享有原抵押物与添附物，根据法律规定，不论是哪种权属状态，抵押权人对抵押财产的权利都及于添附后的抵押物。（2）抵押物添附对抵押权效力的限制。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第四十一条第二款对此进行了明确，当抵押物因添附而增值时，抵押权的效力及于添附物，但抵押权人对增值部分不享有优先受偿权。在实践中如房屋装修、设备改进等情形下，添附后的抵押物与添附物两者难以分割，此时因抵押权效力范围及于添附物，故对添附后财产整体进行拍卖，若抵押财产因添附获得增值，那么抵押权人能够受偿的拍卖款则需从添附物价值扣除相应增值部分。

本案中，刘某某在某公司对生产线设备进行抵押后，对自身所租赁的设备进行改进、维修、翻新等添附，其与某公司事先签订合同约定了设备添附物的归属，添附后的生产线设备形成刘某与

某公司共有的状态，某银行作为抵押权人依旧对于该共有财产整体享有抵押权。但在对该财产进行拍卖后，原设备价值出现了增值，则某银行的优先受偿权并不及于拍卖款的全部，某银行在某公司所抵押财产价值以及增值部分的范围内享有优先受偿权，其优先受偿的范围并不包括刘某添附的财产价值以及增值的部分。

此外，还有一个需要注意的问题，抵押物添附对抵押权效力进行限制的前提条件是“添附导致抵押财产价值增加”，因此，需要对因果关系进行一定的判断。就本案而言，对于机器设备进行维修、更换、扩建，会增加设备的使用

寿命、运行效率等，能够认定该添附与原物的增值有因果关系。类比实践中的其他情形，对房屋进行装修能够增加房屋价值，但房屋增值也会受到周边环境变化的影响，如学校、医院的建设，对此应综合把握，准确认定因添附使原物增值的范围。

编写人：山东省淄博市淄川区人民法院 唐峰 苏晓阳

保证人承担保证责任后主张实现预告登记抵押权的司法审查

—— 某房地产开发有限公司诉陈某某追偿权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

陕西省宝鸡市金台区人民法院(2023)陕0303民初2864号民事判决书

2. 案由：追偿权纠纷

3. 当事人

原告：某房地产开发有限公司(以下简称某公司)

被告：陈某某

【基本案情】

2017年10月，陈某某与某公司、某银行签订《个人房产抵押贷款合同》，约定向某银行借款37万元，期限360个月，以其所购某公司案涉房屋为该笔借款提供抵押担保。同年12月，该抵押权预告登记完成。某公司为该笔借款的连带责任保证人，保证期间自借款到期之日起两年，分期还款的，保证期间按各期还款分别计算，自每期贷款到期日期，计至最后一期贷款到期之日后两年止。借款人取得房屋的权利证明，且贷款人取得抵押物的他项权利证明或证明抵押

权设立的其他文件正本后，保证责任解除。后因陈某某未按期足额支付还款，致某银行从某公司保证金账户扣划多笔款项结清陈某某全部贷款。

案涉房屋已于2022年6月办理了权利人为某公司的不动产权属证明。现某公司起诉要求：(1)判决陈某某连带赔偿本金376998.63元及自2023年3月28日至款清日按银行贷款LPR计算的利息损失(截至2023年4月28日为1146.7元)；(2)判决确认某公司对陈某某所有的案涉房屋拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。

【案件焦点】

1. 保证人承担保证责任后依法取得债权人的权利是否包含抵押权(预告抵押权)；2. 抵押的建筑物所有权初始登记已完成的，保证人能否主张实现建筑物的预告登记抵押权。

【法院裁判要旨】

陕西省宝鸡市金台区人民法院经审理认为：保证人承担保证责任后，除当事人另有约定外，有权在其承担保证责任的范围内向债务人追偿，享有债权人对债务人的权利，但是不得损害债权人的利益。某公司作为连带责任保证人，因借款人陈某某逾期还贷，致其以被扣划保证金的形式承担了保证责任，故某公司在被扣划376998.63元范围内向债务人陈某某追偿的，有事实和法律依据。

保证人承担保证责任后在代付本息范围内可行使抵押权人的权利。关于预告抵押登记是否产生抵押效力，因截至法庭辩论终结前，房屋的正式抵押登记尚未完成，但已办理了所有权首次登记，且权属登记财产与预告抵押登记的财产一致。所有权登记完成后，某公司并未向某银行通知产权登记事项，则无从确认某银行已知道或应知已具备办理正式抵押登记的条件，对应的，办理正式登记的时限也就无从起算，故该案不存在因逾期登记致预告抵押失效的情形。同时，从案涉合同的约定可知，只有在银行取得正式抵押登记他项权证书时，开发商的保证责任方才免除，而相比实现抵押权，开发商以保证金提供担保更

有利于银行及时、低成本维护债权，故在此约定条件下，即使其明知正式抵押登记已具备条件，也无法排除消极协调登记以致保证延续的可能，而在开发商承担保证责任后，其债权已然实现，抵押是否或能否登记已与自身利益无关，故如在案涉条件下机械地适用抵押权登记设立规则，对开发商而言显属不公平。因此，在无确证证实存在其他登记失效的情形时，抵押权自预告登记之日起依法设立，某公司请求实现抵押权的请求，于法有据，予以支持。

陕西省宝鸡市金台区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第二百二十一条、第七百条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五十二条第一款规定，判决：

一、陈某某支付某公司代偿款376998.63元及利息（以376998.63元为基数，自2023年3月28日起按照一年期同期LPR计算至实际给付之日止）；

二、某公司有权对陈某某所有案涉房屋拍卖、变卖所得价款在第一项判决确定的金额范围内享有优先受偿权。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决现已生效。

【法官后语】

商品房预售实践中，银行在借款人提供房屋预告抵押的同时，还会要求开发商向所属开户行账户提供足额保证金，并约定授权扣款条款，由此为借款提供阶段性连带保证责任。这样的规则设置较为周全地保障了银行债权的实现，但通过衡量两种担保方式的变现便利性和可靠性，银行会以合同条款形式将扣划保证金约定为优先选择，如本案中约定银行拿到抵押他项权证书并且确认后保证责任才予免除，导致整个借款期间实际承担担保责任的仅有开发商保证，抵押担保则流于形式。抵押的虚化也相应增加了开发商的追偿风险。在承担保证责任后，开发商如何在现有制度范围内实现追偿权，在司法实践中存在一定争议。

一、保证责任免除的例外约定

一般而言，保证责任的法定免除事由主要有保证期间经过、保证债务时效 经过以及保证人承担保证责任等情形。在商品房预售领域，惯例约定正式抵押

登记完成后开发商阶段性保证责任免除。例如，人民法院案例库“中国农业银行某支行诉来安某房地产开发有限公司、张某某借款合同纠纷案”（入库编号：2023-08-2-103-010）中，借款合同约定开发商的阶段性保证“自借款发放之日起，至办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续后两年之日止”。相比抵押权变现，银行更愿意选择扣划保证金这种快捷、高效的方式，为此会在借款合同中设置若干较为苛刻的条款以规避开发商免除保证责任，使得保证责任存续于整个借款期间。类似约定加重了开发商保证责任，导致银行缺乏办理正式抵押登记的积极性，客观上也为开发商在承担保证责任后主张债权人抵押权以实现全额追偿设置了障碍。但因此类做法以合同文本形式体现时，并不违反相关法律规定，故仍属合法、有效的约定。

二、预告登记状态下实现抵押权的条件

预告登记制度的初设目的在于限制权利人的物权处分权能，保障权利人将来实现物权。该登记不产生物权变动的法律后果，预告抵押在完成正式抵押登记（本登记）前原则上不产生抵押权的效果。但《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五十二条第一款规定，预告抵押符合条件时产生正式抵押的效力，其条件包括：（1）已完成建筑物所有权初始登记；（2）预告登记未失效；（3）权属登记财产与预告抵押登记财产一致等。其中，初始登记是指房屋等不动产的首次登记，实践中一般认为系权利人登记为开发商的物权登记，即俗称的“大本”，而购房者的权属证书是否已办理并不影响抵押登记。预告登记失效的事由包括债权消灭与具备本登记条件之日

起90日内未提交申请。关于90日的起算时间，2023-08-2-103-010号案例 的裁判要旨明确，认定预告登记失效中90日起算点时，应从预告登记权利人知道或应当知道能够进行抵押登记之日起计算。司法实践中，应以房地产开发企业有证据证明已通知预告登记权利人之日，或预告登记权利人明知本登记条件已经具备之日为起算点。在此期间内，如果预告登记权利人提交了办理本登记的申请，且上述其他条件均满足时，即使本登记未完成，但实际上预告登记已产生抵押本登记的效力，抵押权自预告登记之日设立。如预告登记权利人逾期

未申请，则预告抵押登记失效，其无权请求实现抵押权。从司法实践来看，这种情形较为少见，较多的情况是因开发商完成初始登记后未通知银行等原因导致无从确认银行应知或已知可进行本登记，如此，自然不因时限超过引起预登记失效，故商品房预售中大量的预抵押登记可产生正式抵押的效力。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五十二条第一款规定，参考2023-08-2-103-010号案例关于“预告登记权利人是否就抵押财产享有优先受偿权，主要审查是否办理建筑物所有权首次登记、预告登记是否失效两个要件”的裁判要旨，应当认为，类似于本案的情形下，预告抵押登记并不因90日期限的经过而失效，而且应当认定抵押权自预告登记之日起设立，预告登记权利人有权请求就抵押财产优先受偿。这实际上使预告抵押产生了正式抵押的效果。

三、开发商追偿权利如何实现

如前所述，在房屋预售抵押贷款关系中，银行一般通过专项约定优先选择开发商保证担保实现其债权，在借款本息清结后，银行作为债权人无须再主张实现抵押权，而保证人在承担保证责任后依法取得债权人的权利，有权向债务人追偿，且抵押权作为债权的从权利，应随主债权的转移一并转移，保证人在追偿时应享有银行的预告抵押权。经审查预告抵押已具备正式抵押的效力时，即使未经登记，也应确认自预告登记之日起抵押权设立。如抵押物满足变卖、拍卖等流通条件的，对保证人请求在垫付金额范围内实现抵押权的请求，应予以支持。如此，既可让抵押制度发挥既定实效，也能最大限度保障保证人得到全额追偿。

约定的反担保保证期间与主债权保证期间相同时 反担保保证期间的法律适用^①

——某融资担保公司诉某商业城公司等追偿权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

吉林省高级人民法院(2023)吉民再178号民事判决书

2. 案由：追偿权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、再审申请人):某融资担保公司

被告(被上诉人、再审被申请人):某商业城公司、四平市某纺织品经销处(以下简称某经销处)、朱某某等7人

【基本案情】

2019年5月14日,某商业城公司委托某融资担保公司向某银行贷款1500万元,约定贷款期限为2019年5月14日至2019年11月13日;同日,某商业城公司与某融资担保公司签订《委托保证合同》,某融资担保公司与某银行签订《保证合同》,约定某融资担保公司为某商业城公司向某银行的借款提供保证,保证方式为连带责任保证,保证期间为“主债权履行期届满之日起两年”,并约定如果发生代偿,某商业城公司按照月利率1.5%支付利息及担保金额5%支付特别违约金;同日,某经销处、朱某某等7人与某融资担保公司、某商业

^① 入库案例,参见人民法院案例库2023-08-2-143-002。

城公司签订反担保保证合同，约定某经销处、朱某某等7人为融资担保公司对某商业城公司的追偿提供反担保保证，保证方式为连带责任保证，保证期间为“自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止”。2019年5月15日、16日，上述当事人按照以上内容再次就另外两笔1500万元、1000万元借款签订《委托贷款借款合同》《委托保证合同》《保证合同》和《信用反担保保证合同》。后某商业城公司未及时还款，某融资担保公司于2019年11月13日、14日、15日代某商业城公司向某银行偿还本金及利息1591万元、1591万元、1061万元，共计4243万元，某商业城公司已向某融资担保公司还款1000万元，尚欠某融资担保公司代偿本息合计3243万元。

【案件焦点】

约定的反担保的保证期间与保证合同的保证期间相同的，能否视为没有约定反担保的保证期间。

【法院裁判要旨】

吉林省四平市铁西区人民法院经审理认为：某融资担保公司与某商业城公司所签订的各三份《委托贷款借款合同》《委托保证合同》、某融资担保公司与某银行签订的三份对应的《保证合同》及某融资担保公司与某商业城公司、某经销处、朱某某等7人签订的《信用反担保保证合同》，均系签订合同各方当事人的真实意思表示，成立并有效。某商业城公司未按合同约定期限全额还本付息，致某融资担保公司为其代偿本息3243万元（截至2019年11月15日），按合同约定某融资担保公司有权向某商业城公司追偿，某商业城公司应给付所欠某融资担保公司3243万元及利息。

本案中三份《信用反担保保证合同》约定的反担保保证期间均为自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止，即反担保的保证期间起始时间分别是2019年5月14日、15日、16日，该三份反担保保证合同对应的《保证合同》约定的保证期间为主债权履行期届满之日起两年，即起始时间分别为2019年11月13日、14日、15日。根据《中华人民共和国民法典》第六百九

十二条规定，三份《信用反担保保证合同》约定保证期间的起始时间在主合同约定的主债务履行期限届满之前，视为没有约定；且反担保保证合同约定的保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止，没有确定起止时间的年月日，约定不明确。故，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月。因某融资担保公司的起诉和举证已经超过保证期间，故某经销处、朱某某等7人不再承担保证责任。

吉林省四平市铁西区人民法院判决如下：

一、某商业城公司于判决生效之日起十五日内给付所欠某融资担保公司32430000元；

二、某商业城公司于判决生效之日起十五日内给付某融资担保公司2019年11月16日计算至2020年8月19日利息5032325.25元；

三、某商业城公司于判决生效之日起十五日内给付某融资担保公司2020年8月20日之后的利息，以32430000元为基数，按照2020年9月全国银行同业拆借中心授权公布的一年期贷款市场报价利率的四倍即15.4%，计算至本金还清时止；

四、驳回某融资担保公司的其他诉讼请求。

某融资担保公司不服一审判决，提起上诉。

吉林省四平市中级人民法院经审理认为：

1. 关于某融资担保公司与某商业城公司的法律关系问题。某融资担保公司本次诉讼请求并非基于《委托贷款借款合同》向某商业城公司主张偿还借款，而是依据《委托保证合同》的约定，要求某商业城公司偿还代偿资金。本案法律关系应为担保人履行保证责任后的追偿权纠纷。

2. 关于代偿款的利息和违约金数额的问题。某融资担保公司行使追偿权的代偿款总额为3243万元。依据案涉《委托保证合同》约定，“某融资担保公司因履行保证责任而代偿的，有权向某商业城公司及反担保人追偿收回代偿资金本息及相关费用，并自代偿之日起，有权按照月利率1.5%向商业城公司收取代偿资金的利息”“某商业城公司不按主借款合同的约定还本付息导致融资担

保公司为其代偿的，属于重大违约。某融资担保公司在代偿后有权要求某商业城公司支付本合同担保金额5%的特别违约金”，故应分别按照各笔代偿款自代偿之日起以代偿款数额为基数，按月利率1.5%计算至本金还清之日，计算代偿款的利息。案涉三份《委托保证合同》的担保金额为4000万元，故某商业城公司应当支付的违约金应为200万元。

3. 关于反担保保证人是否应承担保证责任的问题。反担保是为保障主债务担保人承担担保责任后的追偿权的实现而设定的担保，适用担保的相关规定。本案中，保证合同约定保证期间为“主债权履行期限届满之日起两年”，故某融资担保公司为某商业城公司的贷款担保期间为自三笔贷款期限届满日2019年11月13日、14日、15日起两年。信用反担保保证合同中约定反担保期间为“本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止”，故反担保的保证期间也是自2019年11月13日、14日、15日起两年。由于二者的保证责任期间相同，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第三十二条第一款“保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的，视为没有约定，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月”的规定，应视为对反担保期间没有约定，本案反担保人的反担保期间应为某融资担保公司在保证期间内履行保证责任之日起6个月，因某融资担保公司在主合同履行期限届满当日即进行代偿，则反担保的保证期间应从主合同到期之日起次日开始计算，即分别从2019年11月14日、15日、16日起六个月，因某融资担保公司于2021年3月12日、24日向反担保人主张权利时已超过反担保保证期间，故反担保人不应承担保证责任。

吉林省四平市中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第三十二条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、维持吉林省四平市铁西区人民法院一审民事判决第一项，即“某商业城公司于判决生效之日起十五日内给付所欠某融资担保公司32430000元”；

二、撤销吉林省四平市铁西区人民法院一审民事判决第二项、第三项、第四项；

三、某商业城公司于本判决生效之日起十五日内给付某融资担保公司代偿资金利息，具体计算如下：1. 2019年11月13日代偿款利息，应自2019年11月14日起以591万元为基数，按月利率1.5%计算至本金还清之日；2. 2019年11月14日代偿款利息，应自2019年11月15日起以1591万元为基数，按照月利率1.5%计算至本金还清之日；3. 2019年11月15日代偿款利息，自2019年11月16日起以1061万元为基数，按照月利率1.5%计算至本金还清之日；

四、某商业城公司于判决生效之日起十五日内给付某融资担保公司违约金200万元；

五、驳回某融资担保公司的其他诉讼请求。

某融资担保公司不服二审判决，申请再审。

吉林省高级人民法院经审理认为：本案的争议焦点为本案是否适用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第三十二条第一款规定，将约定的反担保的保证期间与保证合同的保证期间相同的情况，视为反担保的保证期间没有约定。

一、关于约定的反担保的保证期间与保证合同的保证期间相同的情况是否应适用上述法条的问题

第一，从立法解释的角度进行考察。保证人承担保证责任的前提是主债务履行期限届满，若约定的保证期间早于或等于主债务履行期间，则债权人刚开始有权向保证人主张保证责任，保证期间就已经过，会导致保证人在事实上没有承担保证责任的可能性，保证期间形同虚设。为避免保证合同事实上无法履行的结果，尊重契约效力，法律为此种情形强制规定了六个月的保证期间。故而设置上述法条的目的就是在债权人与保证人对保证期间约定不当时，给予债权人视同双方对保证期间没有约定的利益保护，是为了让合同按照当事人的初

衷成立、发生效力，并非限缩当事人的意思自治的权利。

第二，从文义解释的角度进行考察。首先需要厘清在反担保的情境下，上述法条中所指的“保证期间”与“主债务履行期限”作何解释。反担保保证是为保证人承担保证责任后向债务人行使追偿权而提供担保。故在反担保保证合同的情境下，法条所指的“保证合同”为反担保保证合同，“保证期间”为反担保的保证期间，“主债权”应当为保证人对债务人享有的追偿权，“主债务”为债务人对保证人的债务，而非字面意义上的债务人对债权人的债务。故“主债务履行期限”应当为保证人承担保证责任后，债务人向保证人承担追偿债务的履行期限，而非债务人对债权人的履行期限，更非保证人对债权人的保证期间。故而反担保的保证期间与保证合同的保证期间相同，并非直接等同于法条中所指的“保证期间”早于或者等于“主债务履行期限”。

第三，从适用情形的角度进行考察。保证期间是债权人向保证人行使权利的期间，只要债权人在此期间内行使了债权，保证期间则不再发挥作用，而开始计算诉讼时效。保证人可能在保证期间内承担保证责任，也可能在保证期间结束后的诉讼时效期间内承担责任。保证人自承担保证责任之日起享有向债务人追偿的权利，在保证人未与债务人约定追偿之债履行期限的情况下，保证人在承担保证责任后可以随时向债务人追偿，在反担保的保证期间内也可以随时向连带责任的反担保人追偿。因当事人约定的反担保保证期间与保证期间一致，如果保证人在保证期间内承担保证责任，则保证人享有追偿权之日距离反担保保证期间到期之日尚有一段期间，此期间可能长于六个月也可能短于六个月。仅在保证人在其保证期间到期以后承担保证责任的情况下，反担保的保证期间才会发生等于或早于保证人向债务人追偿权发生之日即“主债务履行期间”，才能符合上述法条适用的前提。

综上，当事人约定的反担保期间与保证期间一致的，并不会必然导致保证责任事实上不可能发生效力这一结果，也就不属于上述法条所要排除的保证责任事实上不可能实现这一情况。只有在部分情况下，才存在适用上述法条的可能，若一概适用上述法条，将可能长于六个月也可能短于六个月的反担保保证

期间强制规定为六个月，是违背当事人意思自治原则的，也违背立法本意。

二、关于本案中反担保保证人是否应向某融资担保公司承担反担保责任的问题

本案中，某融资担保公司于其保证期间起始的2019年11月13日、14日、15日承担了保证责任，从该日期起即获得向债务人某商业城公司的追偿权，某融资担保公司与某商业城公司并未约定追偿债务的履行期间，故某融资担保公司在承担保证责任后可以随时向某商业城公司请求偿还债务，在反担保的保证期间内也可以请求反担保保证人承担连带保证责任。本案约定的反担保保证期间为“本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止”，则反担保的保证期间应当为某融资担保公司承担保证责任之日即2019年11月13日、14日、15日至2021年11月13日、14日、15日。某融资担保公司于2021年3月24日、30日向反担保保证人主张保证责任，并未超过约定的反担保保证期间，反担保人应当向某融资担保公司承担保证责任。

综上，本案不应适用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第三十二条第一款的规定。二审法院适用法律错误，法院予以纠正。

吉林省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条第一款、第一百四十七条、第一百七十七条第一款第二项、第一百八十一条规定，判决如下：

- 一、维持吉林省四平市中级人民法院二审民事判决第一、二、三、四项；
- 二、撤销吉林省四平市中级人民法院二审民事判决第五项；
- 三、被申请人某经销处、朱某某等7人对上述款项向再审申请人某融资担保公司承担连带给付责任（被申请人某经销处、朱某某等7人承担保证责任后，有权向被申请人某商业城公司追偿）；

四、驳回再审申请人某融资担保公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

约定的反担保保证期间与主债权保证期间相同时反担保保证期间的认定，

在司法实践中存在分歧，有观点认为此种情形下应视为对反担保保证期间没有约定。本案作为人民法院案例库入库案例，确立了“约定的反担保保证期间与主债权保证期间相同时不应一概视为反担保保证期间没有约定”的裁判规则。

一、认定反担保保证期间的规范解读

反担保是为保障主债权担保人承担担保责任后实现追偿权而设定的担保。从《中华人民共和国民法典》第三百八十七条第二款“第三人为债务人向债权人提供担保的，可以要求债务人提供反担保。反担保适用本法和其他法律的规定”的规定，可以看出反担保与本担保并不存在本质差异，反担保与本担保在法律适用上是一致的，其担保类型、设立条件、法律效力等方面基本上是相同的。反担保保证作为反担保形式之一，应当适用法律关于保证的相关规定。在反担保保证合同关系中，“主债权”为保证人对债务人享有的追偿权，“主债务”为债务人对保证人所负债务，“保证期间”为反担保保证人承担保证责任的期间。关于约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的效果，根据《中华人民共和国民法典》第六百九十二条第二款规定，应当视为没有约定，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。反担保中，保证期间也可以由当事人约定，但是在约定的反担保保证期间与主债权保证期间相同时，如何认定反担保保证期间，并不能简单依据第三百八十七条第二款直接适用第六百九十二条第二款规定，因为反担保中的“主债务履行期限”并非主债务人对债权人的履行期限，更非债权人对保证人主张保证责任的保证期间，而是保证人承担保证责任后，债务人向保证人履行债务的期限，故在反担保语境下，在约定的反担保保证期间与主债权保证期间相同时，不能简单

依据第六百九十二条第二款一概认为 当事人就保证期间没有约定，而是应当根据个案中保证人与债务人就追偿之债 的履行期限有无约定、保证人实际承担保证责任的情况等因素具体认定。

二、约定的反担保保证期间与主债权保证期间相同时认定反担保保证期间 的裁判规则

本案提供了约定的反担保保证期间与主债权保证期间相同时认定反担保保证期间的裁判规则：保证合同约定的保证期间与反担保保证合同约定的保证期

间一致的，不一定属于保证期间早于或者等于主债务履行期限的情形。当保证人承担保证责任之日在约定的保证期间内时，不属于保证期间早于或者等于主债务履行期限的情形，不应按照《中华人民共和国民法典》第六百九十二条第二款视为对反担保期间没有约定，应当按照反担保保证合同约定确定反担保保证期间；当保证人承担保证责任之日在约定的保证期间之后时，属于保证期间早于或者等于主债务履行期限的情形，应按照《中华人民共和国民法典》第六百九十二条第二款，视为对反担保期间没有约定，反担保保证期间为保证人向债务人或连带反担保保证人主张追偿的合理宽限期届满之日起六个月。

反担保对应的主债权是保证人对债务人的追偿权，这一追偿权只有在担保人实际承担担保责任后才成立，故在保证人未与债务人约定追偿之债履行期限的情况下，保证人在承担保证责任后可以随时向债务人追偿，反担保保证的主债务履行期限应当自保证人承担保证责任之日始，到保证人向债务人主张后的合理宽限期为止。据此，反担保主债务的履行期限的起算点取决于保证人何时实际承担保证责任。《中华人民共和国民法典》第六百九十四条规定：“一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，从保证人拒绝承担保证责任的权利消灭之日起，开始计算保证债务的诉讼时效。连带责任保证的债权人在保证期间届满前请求保证人承担保证责任的，从债权人请求保证人承担保证责任之日起，开始计算保证债务的诉讼时效。”说明保证期间是债权人可向保证人行使权利的期间，只要债权人在此期间内行使了债权，保证期间则不再发挥作用，而开始计算诉讼

时效。例如，债权人与保证人约定的保证期间为两年，那么加上三年的诉讼时效，保证人要承担保证责任的最短期间应当是两年，不存在诉讼时效中止、中断情形下最长是五年，如果发生诉讼时效中止、中断和延长的情形，保证人实际承担保证责任的期间可能更长。因保证人承担保证责任的日期具有不确定性，保证人可能在保证期间内承担保证责任，也可能在保证期间结束后的诉讼时效期间内承担责任，导致保证人的追偿权成立之日即反担保情景下的主债务的履行期限的起点不确定，故约定的反担保保证期间为固定期间，包括与主债权保证期间相同时，会因保证人取得追偿

权的时间不同存在相应的不同情形。

三、约定的反担保保证期间与主债权保证期间相同时认定反担保保证期间的示例

以本案中2019年5月14日发生的1500万元的一笔贷款为例，借款于2019年11月13日到期，债权人与保证人以及保证人与反担保保证人约定的保证期间均为2019年11月14日至2021年11月13日。因保证人在保证期间尚未开始时的2019年11月13日承担了保证责任，其享有追偿权之日保证期间尚未起算，距离反担保保证期间届满之日尚有两年，后保证人于2021年3月24日、30日向反担保保证人主张保证责任，并未超过约定的反担保保证期间，反担保保证人应当向保证人承担保证责任。

如果保证人在保证期间内的2020年1月14日承担保证责任，则保证人享有追偿权之日距离反担保保证期间届满之日尚有22个月。虽然约定的反担保保证期间的起始点早于主债务履行期限，但主债务履行期限届满之日距离约定的反担保保证期间届满之日尚有一段时间，按照约定的反担保保证期间，保证人有充足的时间可以向反担保保证人主张反担保责任。并不会出现反担保保证人在事实上没有承担保证责任的可能性、保证人失去反担保利益的情况，故此种情形中的保证人无须适用《中华人民共和国民法典》第六百九十二条第二款规定，以六个月保证期间予以保护。如果仅考虑约定的反担保保证期间的起始点早于主债务履行期限起始点，而不考虑约定的反担保保证期间结束点晚于主债务履行期限结束点，不具体考察保证人是否实际具有反担保利益，即机械适用上述规定，会导致强制以法律拟制的保证期间替代当事人约定的保证期间，违背立法本意和意思自治原则。故，此时应

当将约定的剩余保证期间作为保证 人向反担保保证人主张保证责任的期间。

如果保证人在保证期间内的2021年9月13日承担保证责任，则保证人享 有追偿权之日距离反担保保证期间届满之日仅有两个月，此时是应当尊重当事 人的意思自治，认定保证期间为两个月，还是应当由法律为当事人拟制一个较 为合理的期间，比如比照早于或等于主债权履行期限的情形，将反担保保证期

间延长至六个月?目前法律及司法解释并没有对于当事人约定期间小于六个月 情况下法律拟制延长的规定。但是通过《中华人民共和国民法典》施行前后对 于约定不明情形下保证责任方式的推定、拟制保证期间的变化,可以看出相较于债权人,立法更倾向于保护保证人的利益。故在出现上述保证期间短于六个月的情形时,笔者认为,还是应当尊重当事人的意思自治,以保证人及反担保 保证人在合同中约定的剩余保证期间作为反担保保证人应当承担责任的期间。

如果债权人在2019年11月14日至2021年11月13日内向保证人主张了保证责任,但保证人在2021年11月13日后的诉讼时效期间内才实际承担保证责任,则保证人在2021年11月13日后才获得向债务人追偿的权利,即取得反担保合同情境下的主债权,但此时约定的反担保保证期间已经过,属于《中华人民共和国民法典》第六百九十二条第二款中规定的保证期间早于或等于主债务 履行期限的情形,从平衡债权人与保证人利益的角度出发,应当适用上述规定, 即适用六个月的保证期间。

编写人:吉林省高级人民法院 谷娟 焦典

内嵌于主债权的连带责任债权纳入最高额
抵押担保债权范围的认定及其消灭后果

—— 谭某某诉某国际贸易(中国)有
限公司 重庆分公司最高额抵押权
案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市九龙坡区人民法院(2023)渝0107民初23289号民事判决书

2. 案由：最高额抵押权纠纷

3. 当事人

原告：谭某某

被告：某国际贸易(中国)有限公司重庆分公司(以下简称某贸易公司)

【基本案情】

2011年10月27日，某科技公司(买方)与某贸易公司(卖方)签订销售框架协议，约定双方以任何方式不时进行的任何一笔买卖交易均适用本合同，另约定某科技公司对其关联企业与某贸易公司合作期间所产生的债务承担连带责任。

2014年4月24日，谭某某向某贸易公司出具无条件的不可撤销的担保函，载明在某贸易公司给予某科技公司的总授信额度的10倍(含本数)的额度内，为某科技公司及其指定的关联公司向某贸易公司所负的一切合法的买卖债务提供不可撤销的连带担保责任。谭某某(抵押人)与某贸易公司(抵押权人)签订《最高额抵押合同(房地产抵押)》，约定谭某某自愿将位于九龙坡区的某处房产抵押给抵押权人，担保某科技公司与抵押权人之间的销售框架协议及其附件和补充协议项下贷款本金金额之和不超过80万元的债权，包括本合同签署之前已经产生的债权，担保范围包括因主合同所产生的所有贷款本金及逾期付款违约金、赔偿金、实现债权的费用、因某科技公司给抵押权人造成的损失和其他应付费。后双方就前述房产办理了抵押登记。

2014年12月12日之前，某贸易公司与某科技公司基于2011年10月27日的销售框架协议合作。之后，某贸易公司与某科技公司的关联公司重庆某公司基于2014年12月22日的销售框架协议合作，该销售框架协议主要载明某贸易公司向重庆某公司供应2011年10月27日销售框架协议中的货物。同时某科技公司于2015年3月24日签订无条件不可撤销担保函为重庆某公司向某贸易公司履行支付货款、违约金等支付义务在8000万元额度内提供连带责任保证。后重庆某公司欠某贸易公司贷款本金8000余万元，经生效裁判文书确认某科技公司在8000万元范围内向某贸易公司承担连带清偿责任。

2021年5月27日，某科技公司向法院起诉要求解除销售框架协议，经法院审理查明，某科技公司与某贸易公司自2015年之后未基于销售框架协议开展业务且双方均无继续履行框架协议的意愿，销售框架协议于2022年5月26日解除。

现谭某某主张某贸易公司与某科技公司之间的销售框架协议已经生效判决解除，主债权消灭担保物权也随之消灭，故提出诉讼请求：(1)某贸易公司对谭某某名下位于九龙坡区的房屋享有的抵押权消灭；(2)某贸易公司立即配合谭某某办理前述房屋抵押登记注销手续。某贸易公司辩称，案涉房屋担保范围还包括某贸易公司对某科技公司关联公司重庆某公司的债权，该债权并未结清，故其享有的抵押权不应消灭。

【案件焦点】

1. 某国际贸易公司对某科技公司关联企业享有的连带责任债权能否纳入最高额抵押担保债权范围；2. 前述连带责任债权如纳入最高额抵押担保债权范围，连带责任债权的债务人向最高额抵押权人出具新的不可撤销担保函，是否具有消灭连带责任债权的效力，进而在原债权已消灭的前提下导致最高额抵押权消灭。

【法院裁判要旨】

重庆市九龙坡区人民法院经审理认为：谭某某与某贸易公司签订的《最高额抵押合同(房地产抵押)》中关于抵押权的担保范围约定为“《销售框架协议》及其附件和补充协议项下贷款本金金额之和不超过80万元的债权及因主合同所产生的所有贷款之本金及逾期付款违约金、实现债权的费用等”。该《销售框架协议》是2011年10月27日某科技公司与某贸易公司所签，授信额度明确为不超过80万元。某贸易公司提及的重庆某公司尚欠货款系重庆某公司与某贸易公司在履行双方于2014年12月22日签订的《销售框架协议》中所发生，某科技公司于2015年3月24日向某贸易公司出具《无条件的不可撤销的担保函》确认在8000万元范围内向某贸易公司承担连带清偿责任，系针对某贸易公司与重庆某公司签订的《销售框架协议》作出的新的意思表示，并非某科技公

司与某贸易公司签订的《销售框架协议》及其补充协议等所约定，且若将某贸易公司要求某科技公司对其关联企业负担的债务承担连带责任的请求也纳入抵押权的担保范围，将无限扩张抵押权的担保范围，使抵押人的利益遭受减损。同理，即使根据谭某某向某贸易公司出具的《无条件的不可撤销的担保函》，某贸易公司对谭某某享有的也仅为连带责任保证债权，不属于《最高额抵押合同（房地产抵押）》约定的抵押权的担保范围。故，法院对抵押权的担保范围确认为某贸易公司基于与某科技公司签订的合同对某科技公司享有的货款本金及违约金等费用的请求权。

对谭某某而言，某科技公司与某贸易公司之间的主债权债务已结清，其抵押担保的主债权消灭，故某贸易公司对谭某某享有的抵押权也消灭。某贸易公司作为案涉房屋的抵押权人，现其抵押权消灭，协助抵押人谭某某办理抵押登记注销手续系其合同义务，故对谭某某要求某贸易公司协助办理案涉房屋抵押登记注销手续的诉讼请求，予以支持。

重庆市九龙坡区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国物权法》第一百七十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

一、被告某贸易公司对原告谭某某名下位于重庆市九龙坡区案涉房屋享有的抵押权于本判决生效之日消灭；

二、被告某贸易公司于本判决生效之日起三十日内协助原告谭某某办理重庆市九龙坡区案涉房屋的涂销抵押手续。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

在以销售框架协议为蓝本的长期性买卖合同领域中，债权人作为强势经济主体具有绝对的话语权，在主合同中通常约定债务人对其关联企业与债权人合作期间产生的债务承担连带责任，债务人作为弱势方不得不接受。基于该连带责任债权内嵌于主合同的形成方式，可称之为内嵌连带责任债权，由此导致销售框架协议中包含两个法律关系，即原债权法律关系和内嵌连带责任债权法律

关系。本案即涉及内嵌于主债权的连带责任债权纳入最高额抵押担保债权范围的认定及其消灭后果的法律适用问题。

一、最高额抵押担保债权范围包含内嵌连带责任债权的正当理据

首先，内嵌连带责任债权具有不特定的动态属性。最高额抵押权的本质在于其所担保的债权是不特定债权。内嵌连带责任债权依附于最高额抵押权人与债务人关联企业的基础合同履行。基础合同在履行期间可能不断发生或消减而呈现出连续性与变动性，致使内嵌连带责任债权在最高额抵押权人未实际向债务人主张时也始终处于不特定状态，符合最高额抵押权不特定的动态属性。其次，内嵌连带责任债权交易符合最高额抵押权设立的便利主义。最高额抵押权的设立系为保障融资担保的便捷与效率，一次设定即可涵括担保陆续发生的不特定债权，以供反复融资的担保。内嵌连带责任债权系交易主体基于建立长期性合同关系而订立框架协议，将债务人对其关联企业与债权人合作期间产生的债务承担连带责任的债权作为原债权的组合物，共同纳入最高额抵押担保债权范围，符合最高额抵押权设立的便利主义。最后，内嵌连带责任债权并非无限制的担保债权。当然，认可内嵌连带责任债权将无限扩大担保债权范围，侵害最高额抵押权人的利益。从逻辑自治角度而言，只要解决担保债权无限扩大的问题，内嵌连带责任债权纳入最高额抵押担保债权范围就具有正当性。内嵌连带责任债权存在的初衷即为将与原债权相关联的债权纳入担保范围，其形成上已经通过“关联”标准进行了限制。

本案所涉最高额抵押权人某贸易公司与债务人某科技公司的连续性交易合同即属典型。囿于以某科技公司名义参与销售框架交易可能造成货物供应不足，某贸易公司基于长期以来在双方之间累积的信赖，采取与某科技公司关联企业重庆某公司延续开展同一性质买卖交易，再约定某科技公司对其关联企业重庆某公司债务承担连带责任。此处的连带责任内嵌于某科技公司与某贸易公司的销售框架协议之中。

二、最高额抵押担保债权范围中内嵌连带责任债权的甄别标准

首先，内嵌连带责任债权与原债权具有性质关联性。一方面，内嵌连带责

任债权所依附的基础合同关系，被限定为债务人关联企业与最高额抵押权人之间因与原债权相同或相关交易所产生的债务。此处的关联性内涵界定可以包括事实层面的限定，如基础合同关系与原债权均系针对某类产品交易而形成的债权债务交易安排；交易形态的限定，如基础合同关系属于原债权基于文本解释推演出的具体子类型交易模式。另一方面，性质关联不能作扩大解释。对于“债权人对债务人的一切债权”“债权人对于债务人基于商业交易关系的债权”等约定的表述，虽体现出二者的关联性，但并未就内嵌连带责任债权作实质性限定，无法达到使抵押人在客观上可以明确区分所担保债权范围的标准，不能认定为具有性质关联。

本案中，销售框架协议约定某科技公司就其关联企业重庆某公司对某贸易公司负担的债务承担连带责任，因某贸易公司与重庆某公司之间的延续交易，属于销售框架协议中约定的与原债权同性质的业务即货物买卖合同关系，可以认定为性质关联。

其次，内嵌连带责任债权与原债权具有主体关联性。一方面，形式上的主体关联。债务人与其关联企业在主体构成上存在关联关系，即债务人公司控股股东、实际控制人、董事、监事与其直接或者间接控制的关联企业的前述人员具有身份上的重合关系。同时，内嵌连带责任债权的权利义务主体客观上也呈现出与原债权权利义务主体相对应的表象，即原债权中的债权人基于框架协议享有原债权请求权和内嵌连带责任债权请求权。另一方面，最高额抵押权人、抵押人、债务人的实质交易模式印证三者存在法律或事实上的主体牵连性。最高额抵押权人基于对债务人及其关联企业的信任及依赖，客观上知道或应当知道不同债务主体产生的债权关系、内容，并具有一定的掌控力，采取“合并方式”

将不同债权纳入同一销售框架协议之中，以确保最高额抵押权人可借由主 合同一并实现相关债权利益。最高额抵押人一旦作出授信允诺，就有义务预见 未来不确定债权存在的风险及隐患，其应当尽到足够的注意义务，在对债务人 资质审核方面承担责任。将债务人对其关联企业与债权人合作期间产生的债务 承担连带责任内嵌于原债权之下，已在一定程度上通过主体关联实现了担保债

权范围的扩张，但此种扩张并未损害抵押人的预期，符合最高额抵押权设立的宗旨。

本案中，内嵌连带责任债权的债权人、债务人与最高额抵押权所担保主债权合同中的债权人、债务人分别系同一主体，债权人为某贸易公司、债务人为某科技公司；连带责任债权所依附的债权内容，系债务人的关联企业为主债权人之间开展的与销售框架协议项下的货物买卖合同关系同性质的交易，可以认定连带责任债权与最高额抵押担保主债权具有关联性。

三、最高额抵押权实现受限于内嵌连带责任债权的基础原因关系变更

首先，内嵌连带责任债权的确定依照原债权确定的时间点决定。《中华人民共和国民法典》第四百二十三条规定“新的债权不可能发生”构成最高额抵押权确定的事由。在原债权基于业务不再开展已确定不再产生的情形下，可以认定为双方合意终止，最高额抵押担保的原债权不再具有流动性，属于构成债权确定的事由。内嵌连带责任债权本身系由于最高额抵押权人的优势地位而设立的附属债权，依次从属于最高额抵押权人对债务人关联企业的债权，进而再从属于原债权。内嵌连带责任债权基于与债务人责任承担的连接，与原债权具有组合性。根据民法学理，数项债权结合的情形下，其中一项债权依存于另一项债权存在，若原债权不成立、无效、撤销、解除或不再发生时，依附于其的“子”债权、“孙”债权也应当同其命运。在此逻辑推演之下，内嵌连带责任债权的确定由原债权确定的时间点决定。

其次，内嵌连带责任债权确定后，其消灭导致最高额抵押权消灭。最高额抵押担保债权的确定意味着最高额抵押权转化为普通抵押权，此时的最高额抵押权与确定后内嵌连带责任债权具有从属关系，内嵌连带责任债权消灭则最高额抵押权消灭。本案中，因某科技公司的关联企业重庆某公司已于2014年12月22日签订销售框架协议，由某贸易公司向重庆某公司供应货物，某科技公司不再开展该项业务，则原债权确定不发生时间为2014年12月22日。某贸易公司对某科技公司享有的连带责任债权基于原债权不发生而得以确定，即连带责任债权确定时间系原债权确定不发生的时间2014年12月22日。之后，最高额

抵押担保的内嵌连带责任债权参照普通抵押权的相关规则予以认定，内嵌连带 责任债权消灭将导致最高额抵押权消灭。

最后，新担保函具有消灭内嵌连带责任债权的效力。本案中，2015年3月24日，某科技公司向某贸易公司出具担保函，为重庆某公司向某贸易公司履行 支付货款等义务提供连带责任保证，双方虽未明确约定担保函成立后内嵌连带 责任债权消灭，也未约定担保函中载明的担保责任承担后内嵌连带责任债权的 法律关系消灭。但考虑到某科技公司出具的担保函与内嵌连带责任债权性质相似，某贸易公司未提出异议，可以视为某贸易公司同意由内嵌连带责任债权变 更为连带责任保证，内嵌连带责任债权据此消灭。一方面，在新担保函出具之 时，某贸易公司同意某科技公司新的保证意思表示，基于新的保证意思与内嵌 连带责任债权的内容具有重叠性，为避免同一债务人遭受重叠的债务负担，再 结合重庆某公司与某贸易公司进行的交易实质系延续某科技公司与某贸易公司的交易，可以视为某贸易公司已作出选择连带责任保证的决定。另一方面，从 某科技公司承担责任的依据来看，重庆某公司并未依据内嵌连带责任债权向某 科技公司主张债权，而系基于新担保函向某贸易公司主张连带清偿责任，可以 推论此种变更系某贸易公司同意的债的更改措施，而并非存在担保措施。综上，可以视为内嵌连带责任债权于某科技公司出具新担保函之时消灭。据此，在内 嵌连带责任债权消灭后，最高额抵押权也据此消灭。

编写人：重庆市九龙坡区人民法院 樊亚琴 李静

五、占有保护纠纷

63

在占有保护诉讼中法院应当查明客观上是否存在占有的事实

—— 某药业有限责任公司诉王某等占有保护案

【案件基本信息】

- 1. 判决书字号
四川省凉山彝族自治州中级人民法院(2024)川34民终924号民事裁定书
- 2. 案由：占有保护纠纷
- 3. 当事人
原告(上诉人):某药业有限责任公司(以下简称某药业公司)
被告(被上诉人):王某、徐某某、魏某某
第三人(被上诉人):四川某国有资产投资开发有限责任公司(以下简称某国资公司)

【基本案情】

2022年11月,某国资公司对案涉闲置国有资产进行公开竞价招租并发布招租公告。某药业公司通过“部分闲置国有资产公开竞价招租会”取得某商场的五年租赁权,时间为2023年1月1日至2027年1月31日。因该资产招租后,新老承租方无法顺利完成交接工作,经过三方座谈协商,达成一致意见,原租

赁期的开始时间调整为2023年3月15日。在此之前，魏某某与某国资公司签订《某商场摊位、管理租赁合同》取得某商场一楼所有摊位及公共空间的租赁权，租赁期限：2018年9月1日至2022年12月31日。

魏某某于2022年3月15日将案涉摊位租赁给王某，租赁期限为2022年3月15日至2023年3月15日，租金17000元及菜摊物业费合计20720元，该摊位一直由王某的母亲徐某某实际使用。2023年3月14日，魏某某与某药业公司对某商场进行了移交。魏某某将某商场内水电费余额、收取租金余额支付给了某药业公司，同时将电表记录本、门卫室及水表的钥匙移交给某药业公司、涉及19家摊位及门面口头移交给了某药业公司。某药业公司将收回的摊位又重新进行了转租。

2023年3月15日以后，徐某某继续使用案涉摊位至今。现，某药业公司因自己需要使用案涉摊位，曾口头通知徐某某搬离该摊位，现以占有保护为由诉至法院。

某国资公司陈述，在租赁某商场一楼所有摊位给某药业公司时，未进行清场，也未将案涉租赁房屋交付给某药业公司。徐某某对某药业公司上涨的租金无异议，但要求继续租赁案涉摊位或某药业公司在赔偿自己损失后同意搬离。

【案件焦点】

原告是否取得案涉占有的事实。

【法院裁判要旨】

四川省会理市人民法院经审理认为：根据法律规定，占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物；对妨害占有的行为，占有人有权请求排除妨害或者消除危险；因侵占或者妨害造成损害的，占有人有权依法请求损害赔偿。占有保护请求权的基础是占有的事实，原告需要举证证明其对案涉标的享有合法占有的权益并且已经实际占有。本案中，某药业公司与某国资公司签订了《资产租赁合同》，双方存在租赁合同关系。作为出租方的某国资公司（甲方）即负有将租赁物交付给承租人某药业公司（乙方）的义务。根据《资

产租赁合同》第八条特别约定，“甲方配合协调租赁资产相邻人、水、电供应者的关系。甲方将资产交付给乙方使用后，乙方管理使用期间所产生的水、电、日常维护等一切费用及安全问题由乙方承担”，根据庭审查明的情况，某国资公司并未将案涉摊位实际交付给某药业公司使用，且某药业公司也未实际占有案涉摊位。故，某药业公司以占有保护为由主张王某、徐某某、魏某某排除对案涉摊位房屋占有使用的妨害，立即搬离该处摊位房屋的诉讼请求，无事实和法律依据，不予支持。

某药业公司要求王某、徐某某赔偿其摊位房屋的房租并支付资金占用利息，因某药业公司与某国资公司签订了《资产租赁合同》，王某、徐某某不是合同的相对方，某国资公司与王某、徐某某不存在合同关系，根据合同相对性原则，某药业公司无权向王某、徐某某主张租金及资金占用利息，故对某药业公司本项诉讼请求不予支持。

四川省会理市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百六十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回原告某药业公司的诉讼请求。

某药业公司不服一审判决，提起上诉，但是收到一审法院送达的《交纳诉讼费用通知书》后，未在7日内向法院预交案件受理费，亦未提出书面缓交、减交或免交上诉案件受理费的申请，且其亦向二审法院提交撤诉申请。

四川省凉山彝族自治州中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十八条规定，裁定如下：

本案按上诉人某药业公司自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。

【法官后语】

占有是一种事实，而非权利，所以在占有保护纠纷中法院无须查明占有人是否有权占有，只要查明客观上存在占有事实，该占有事实就能受到保护。人

们对物的现实占有状态应受到保护，任何人不能以私力改变占有现状。占有保护纠纷之诉是以恢复原状为目的的应急措施，并不从根本上解决当事人之间的矛盾。无论原告的占有诉请是否能得到保护，如原告或相对方认为其对争议物拥有实体权益，可基于本权另行寻求权利救济。原《中华人民共和国物权法》设专编规定“占有”，初步确立起占有保护制度，不仅明确规定占有保护请求权制度，而且明确规定占有受侵权责任制度的保护。《中华人民共和国民法典》承继了上述占有保护制度，如何在审判中准确把握占有保护请求权的相关认定标准，是实践中值得研究探讨的重点问题。

一、法律对占有进行单独保护的目的在于维护社会和平秩序

占有是当事人对标的物在事实上的管领状态，是事实而非权利。一般而言，法律保护的是权利而不是事实。之所以对占有这种事实进行保护，主要是基于以下两个方面的原因：一是为维护社会的和平秩序，防止暴力性私力救济的发生。占有虽为事实，但意味着社会中人和人之间对物占有的秩序，如果不对其进行司法保护，当事人运用私力救济可能导致暴力事件的发生，破坏物之占有的和平秩序。二是可以间接地保护包括物权在内的本权。所谓“本权”，是指法律赋予当事人占有标的物的权利，主要是物权，如所有权，但也包括部分债权，如租赁权。正是因为对占有进行保护具有上述价值，所以人们对物的现实占有状态更应受到保护，任何人不能以私力改变占有现状。即便对于物的现实占有状态与法律的应有状态不符，也不允许擅自以私力加以改变。即使是正当的权利人，如果允许他们可以任意否定这一占有状态，和

平的社会秩序必然会遭到破坏。这正是物权保护对占有进行单独保护的立法初衷。

二、占有保护纠纷诉讼的审查要点

原告诉请占有保护应当以其事实上占有标的物且该占有被妨害或侵害为前提，故在占有保护纠纷诉讼中，法院首先应当审查原告是否占有案涉标的物。如原告未取得案涉占有，则驳回其诉讼请求。如原告已取得案涉占有，进一步审查被告是否有侵害行为（如侵占、妨害、损毁等）。本案中，原告某药业公司需举证证明其对案涉场地取得占有。但原告仅提供了与某国资公司的租赁合同

同来证明占有的事实，该合同仅能证明双方之间有租赁合同关系，不能证明出租人已将案涉房屋交付即转移占有给承租人，结合庭审情况，原告某药业公司从未实际占有过该案涉摊位，该案涉摊位一直是由被告徐某某在占有、使用。故无须进行下一步的审查，驳回原告诉讼请求即可。

可见，对占有保护纠纷无须查明占有人是否有权占有。目前，学界通说认为，占有是一种事实，是对物事实上的控制与支配，强调一种事实状态，而不是关注权利本身。所以，占有才能够独立于所有权和他物权而单独受到保护。因为占有是一种事实，而非权利，所以在占有保护纠纷中法院无须查明占有人是否为有权占有。有权占有，是指基于法律规定或合同约定对某物进行的占有，又称有本权的占有，包括基于合同、物权或特定身份关系而享有的占有。反之，非基于本权或者欠缺法律上的原因而占有某物就是无权占有，如承租人在租赁期满后仍占有租赁物等。在占有人的占有受到侵害时，占有人是有权占有还是无权占有，无权占有中是善意占有还是恶意占有，法院均无须审查，只要查明客观上存在占有事实，就可对该占有事实予以保护。

三、占有保护纠纷的裁判结果不妨碍权利人另行主张实体权益

因为对占有的保护不考虑占有的实体权利，占有人只需对占有事实和权利受侵害的事实进行举证即可，从举证的难易程度来看，相比基于本权进行的诉讼容易许多。这样，占有人通过提起占有保护纠纷之诉，可以使受侵害的权益及时得到维护。但占有保护纠纷之诉毕竟是以恢复原状为目的的应急措施，只能使物的现实占有人继续保持其原有的占有状态，并不能从根本上解决当事人之间实体权益的归属。所以，占有人的占有得到保护后，如另一方认为其对争议物拥有实体权益，可基于本权另行起诉。

编写人：四川省会理市人民法院 余香 程雨

占有保护纠纷应当考量双方的占有事实，而非所有权状态

——赵某某诉陈某某占有保护案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省邓州市人民法院(2023)豫1381民初1566号民事判决书

2. 案由：占有保护纠纷

3. 当事人

原告：赵某某

被告：陈某某

【基本案情】

2014年8月30日，赵某某与河南某置业有限公司（以下简称某置业公司）签订《商品房认购协议书》，认购某小区案涉房屋，建筑面积为120.96平方米，总价款为374734元。协议签订当日，赵某某交付定金2万元，9月29日，赵某某向某置业公司支付购房款8万元并取得案涉房产的钥匙。2021年8月，陈某某通过换锁方式对案涉房产进行装修，赵某某得知后通过物业更换门锁，并于2022年1月24日向某小区的物业管理人某物业公司交纳物业费、燃气初装费。2022年9月25日，陈某某、赵某某先后派人入住案涉房屋，形成两家入住同一户情形。赵某某报警后公安机关以双方存在民事纠纷为由未立案。赵某某遂提起本案诉讼。

案外人夏某某与王某某于2011年开始合伙开发案涉房屋所在的某小区房地产，但未完善有关开发、预售等行政许可手续。夏某某利用其控制的某置业公

司对外销售某小区的房产，王某某也对外出售该小区的房产，导致出现“一房多卖”的情况。

陈某某与案外人高某某系夫妻关系。王某某欠高某某借款100万元未还，法院生效民事判决对该笔债权本息予以确认。2016年1月11日，王某某将案涉房产以60万元的价格抵偿给陈某某，双方签订《房屋买卖合同》，备注“此款抵某小区工程款”，王某某并出具收条认可收到某小区房款60万元整。

【案件焦点】

双方基于无效合同占有使用房屋时，能否向对方主张占有保护请求权。

【法院裁判要旨】

河南省邓州市人民法院经审理认为：首先，从案涉房屋的来源上看，案涉房屋所在楼盘由王某某、夏某某等人共同投资建设，并非由某置业公司开发。案涉房屋所在楼盘未取得相应的建设手续，未取得预售许可，亦未办理不动产登记。依据现有证据，不能够证明王某某、夏某某等人如何分配所建成房屋，亦不能确定谁享有对案涉房屋的处分权。其次，从当事人所述的购房过程来看，赵某某表示其于2014年与夏某某控制的某置业公司签订《商品房认购协议书》购买案涉房屋，并按照约定支付了首付购房款，案涉小区的物业公司也将案涉房产的钥匙予以交付；陈某某表示其于2016年与王某某签订房屋买卖合同，以购房款抵案外人合伙开发某小区项目所欠的工程款，但实际上王某某并未向陈某某交付房产。再次，从双方产生纠纷的根源上来看。赵某某与陈某某对案涉房屋产生的纠纷，实质上系夏某某与王某某对案涉房屋如何分配产生的纠纷。要解决赵某某与陈某某之间的纠纷，应先解决夏某某与王

某某之间对案涉房屋 的纠纷。在王某某与夏某某之间的纠纷尚未解决，案涉房屋处分权不明的情况 下，不能直接处理赵某某与陈某某对案涉房屋的纠纷。最后，从解决纠纷的途径上看。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定：“出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的 商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，

可以认定有效。”因案涉房屋所在楼盘未取得预售许可证明，故赵某某、陈某某各自提供的房屋买卖合同均应认定无效。《中华人民共和国民法典》第一百五十七条规定：“民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。”在合同无效的情况下，赵某某、陈某某均不能直接对案涉房屋主张权利，即其主张享有的权利不合法、不受法律保护，其应分别向自己的前手王某某或某置业公司（夏某某）主张。所以，赵某某在案涉房屋买卖合同无效、陈某某已对案涉房屋进行装修的情况下提起诉讼，主张陈某某构成侵权，要求陈某某搬离案涉房屋、赔偿其误工费及交通费损失的请求，缺乏事实及法律依据，同样，陈某某亦无权主张赵某某构成侵权、要求赵某某搬离案涉房屋。

河南省邓州市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百五十七条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

驳回原告赵某某的诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

占有保护之诉本质上是为了维护稳定的占有事实，而非要明确背后的权利义务关系。即使双方均系无权占有，若有一方能够证明其已占有争议物，则也应当对其占有状态进行保护，反之，若双方均无法证明其已占有争议物，则双方均无法依据占有状态行使占有保护请求权。

在司法实践中，因权利人的占有源于某种特定的权利，其可直接基于所有权等权源对占有进行权利主张，故基于占有的事实状态提出保护主张的当事人多属于无权占有人。在此类案件中，人民法院需在当事双方均无合法权利来源

证明的情况下，对占有人进行识别，确认非占有人的侵占事实，进而对占有保护请求权进行司法保护，回复占有人对占有物的占有。

占有人仅需证明占有存在即有权主张返还原物请求权。占有作为占有人对不动产或者动产实际控制与支配的事实状态，其本身并不一定反映产权关系。占有制度所保护的也仅仅是占有的事实状态，而非通过确认、保护占有而对占有物进行权属判断，故占有人提出返还原物请求权仅以其长期、持续、和平地占有标的物为前提。在司法实践中，权利保护需以权利人提供相应的权利依据为前提，可能存在举证困难的问题，但在占有制度的框架内，是有权占有还是无权占有，是基于债权、物权还是人身关系的占有均无须考虑，占有人仅需证明其持续稳定地实际占有标的物这一事实即可，这无疑减轻了当事人的维权负担。本案中，现有证据均不能证明赵某某、陈某某等人为案涉不动产的合法产权人。原告赵某某基于占有提起诉讼，仅需提供证据证明其对案涉房屋的占有事实即可。

占有应当达到对物的实际管领支配。对物的实际管领支配，除了应当存在占有的意思及达到对占有物的直接支配状态之外，还应依社会观念并考虑外部可以认识的空间、时间关系，就个案加以认定。所谓空间关系，是指人与物在场合上须有一定的结合关系，足以认定该物为某人事实上管领。例如，居住房屋、佩戴首饰当然为占有。所谓时间关系，是指人与物在时间上须有相当的连续性，足以认为该物为某人事实上所管领。短暂性的控制不成立占有，如在餐厅使用餐具不构成对餐具的占有。因此，法院在审理占有保护纠纷时，应当重点围绕占有人对是否实际占有标的物，以及若占有事实存在则侵夺人是否侵夺占有人的占有这两个方面进行审查。

本案中，赵某某虽在2014年取得房屋钥匙，但并未实际入住装修、交纳相关物业费用，对案涉房屋未存在一定的结合关系。在被告陈某某通过换锁方式对案涉房产进行装修后，赵某某又通过物业更换门锁并交纳物业费用，直至在陈某某派人入住案涉房屋的当日，也随后派人入住案涉房屋。双方在此期间虽以更换门锁的行为宣示占有，但双方均未实际入住，亦未形成对案涉房屋时间

相当的持续性管领，因此双方均未形成对案涉房屋的占有事实。因此，法院最终判决驳回原告的诉讼请求。

编写人：河南省邓州市人民法院 周磊

65

非集体经济组织成员在宅基地上 建造的房屋被强占的，有权主张占有保护

——胡某某、张某诉王某某占有保护案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省湘阴县人民法院(2023)湘0624民初1664号民事判决书

2. 案由：占有保护纠纷

3. 当事人

原告：胡某某、张某

被告：王某某

【基本案情】

胡某某和张某系夫妻关系，王某某系张某的亲戚。经王某某介绍，2020年3月18日，甘某某与胡某某签订《购买宅基地协议书》及《附加协议》，约定胡某某以488000元价格购买案涉宅基地用于建房，甘某某同意协助胡某某打好该地基础桩，胡某某补偿甘某某相关费用15000元。同日，胡某某向甘某某支付480000元，约定余款8000元于2021年8月30日前付清。张某称其将打桩等费用微信转账并委托王某某之妻付给甘某某，大概有20000元。王某某认可张某某通过王某某妻子转账给他15000元，用于案涉房屋建设。2021年6月26

日，胡某某向甘某某付清合同余款8000元。

2021年2月23日，张某某与案外人杨某某签订《建筑施工承包合同书》，约定将案涉宅基地工程施工以包工不包料的方式承包给杨某某。4月13日，胡某某、张某以甘某某的名义为案涉宅基地办理了《建设工程规划许可证》，建设项目名称为住宅。案涉房屋于同年中秋完工，一共两缝五层，一楼是门面，二楼到五楼是住房，合计花费1203000元。现在一楼是胡某某用于经营，二楼是王某某在2021年12月23日安装了入户门并上锁控制，没有支付对价，三楼至五楼已出租给他人。

王某某称，案涉房屋二楼是他所有，因为案涉房屋的地基洽谈、加固地桩、房屋建设等都是他参与的，早在2020年3月左右，胡某某、张某口头承诺二楼以成本价出卖给他，他也垫付建房开支81846元。胡某某、张某称，他们将打桩包干给甘某某，只是在打桩时请王某某监工三天，2020年3月张某不在家，合同都是胡某某一个人签字，胡某某一人不能向王某某承诺出售二楼。

王某某认可其对案涉房屋二楼有改造、损坏行为。经评估：案涉房屋损失的价格在价格评估基准日（2022年9月3日）的评估值为6954元。张某支付评估费用3000元。

【案件焦点】

胡某某、张某提起本案诉讼的权利基础是所有权还是占有事实。

【法院裁判要旨】

湖南省湘阴县人民法院经审理认为：案涉房屋所占土地为集体土地，胡某某、张某提交的案涉房屋建设工程规划许可证是以原使用权人甘某某的名义办理，胡某某、张某并非案涉房屋所在地集体经济组织成员，案涉房屋也未办理不动产权证，所有权尚不明确，故对胡某某、张某主张的对案涉房屋享有所有权，不予支持。但是，甘某某将案涉房屋所占土地出卖给胡某某、张某，签订《购买宅基地协议书》，收取购地款488000元，也允许胡某某、张某在所占土地上建设案涉房屋，胡某某、张某实际投入资金建造案涉房屋，同时也是案涉

房屋的最初占有人，合法享有对案涉房屋的占有。王某某在未对胡某某、张某占有案涉房屋的依据通过法定程序确认无效或撤销的情况下，未经胡某某、张某同意，对案涉房屋二楼加装入户门，进行装修，占用至今，侵犯了胡某某、张某对案涉房屋二楼的占有，对胡某某、张某请求判令王某某停止对案涉房屋的侵害行为、拆除案涉房屋二楼入户门的主张，予以支持。王某某辩称，胡某某、张某口头承诺将案涉房屋二楼以成本价出售给他，但胡某某、张某并未认可，王某某也未提供证据证实其已向胡某某、张某支付相应房屋价款，不予支持。如王某某对胡某某、张某购买案涉房屋所占土地或者胡某某、张某未按承诺向其出售案涉房屋二楼持有异议，可以通过合法途径予以解决，而不是通过私力救济对案涉房屋的占有现状加以改变。

关于胡某某、张某诉请王某某赔偿案涉房屋的财产损失6954元及评估费用3000元的问题。胡某某、张某因王某某侵占案涉房屋二楼造成的损害，应理解为对胡某某、张某占有利益的损害。胡某某、张某提供的《价格评估报告》是对案涉房屋损失的价格进行评估，并非单一指向案涉房屋二楼，也不能充分证实是王某某造成的损失，但王某某认可其对案涉房屋二楼进行了改造，而王某某私自对案涉房屋二楼进行装修，必然会破坏房屋原状，胡某某、张某的损失客观存在，法院酌情认定王某某向胡某某、张某赔偿相关损失3000元。

湖南省湘阴县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条第一款第一项、第二项、第八项，第四百六十二条，第一千一百六十五条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

一、限王某某于本判决生效之日起十日内停止对胡某某、张某占有的案涉房屋的侵害行为；

二、限王某某于本判决生效之日起十日内拆除由其在胡某某、张某占有的案涉房屋二楼安装的入户门；

三、限王某某于本判决生效之日起十日内向胡某某、张某赔偿相关损失3000元；

四、驳回胡某某、张某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未提起上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

一、占有人基于占有事实对占有标的物享有占有利益

本案的主要争议焦点在于不具有集体经济组织成员身份的原告购买案涉宅基地、建造案涉房屋、借名办理建设工程规划许可证，但尚未取得不动产权证的情况下，原告提起本案诉讼的权利基础是所有权还是占有事实。《中华人民共和国民法典》在所有权保护条款之外，单独设立占有保护条款，针对的是不同情形下物权保护的需要。占有作为一种事实状态，受法律保护，仅需占有人原本有占有的事实即可，而非确定的权利，不问其是否具有正当权源，旨在维护市场交易秩序的稳定、有序，防止个人以私力改变和扰乱占有物的现状，对已成立的事实状态予以保护，如相关权利人对占有人的权利状态质疑，均应通过合法途径予以解决。本案中，虽然原告不具备案涉房屋的宅基地使用资格，借名办理建设规划许可证也存在建设违章建筑之嫌，但本案不宜也无须对案涉房屋进行确权，因为原告已举证证明其系案涉房屋的实际出资建造人和初始占有人，有占有案涉房屋的意思表示和事实，不影响法院直接对占有的事实提供法律保护，赋予占有人救济性权利，维持占有的事实状态。

二、占有人基于占有利益受损可以主张损害赔偿

损害赔偿请求权属于债权保护方法，占有受到侵占或者妨害，造成占有人的财产利益损失的，成立侵权行为，占有人产生侵权损害赔偿的请求权。占有虽非一种权利，但也属于法律所保护的一种财产利益，不受他人非法侵害，侵害占有的主体应负侵权的损害赔偿赔偿责任。本案中，被告没有合法正当的理由占有、使用案涉房屋二楼，主观上存在过错，客观上破坏财产原状，损害了原告因占有对案涉房屋享有的合法财产利益，在填补原告因占有被侵夺或妨害而产生的不利益时，要对受害人的权益保护与行为人的自由尊重进行平衡，确保在维护权利人的合法利益的同时，不对行为人的自由造成过分的限制。本案同时

考虑到双方的亲戚关系，鉴于被告对案涉房屋二楼的装修并非不可逆的损害，酌情认定原告的相关损失为3000元。

三、民事责任承担方式的谦抑性

随着经济社会的迅速发展，社会需求的不断多样化，民事责任的承担方式也在适应人们的多元化需求。承担民事责任的方式，各有特点和相应的功能，既可以单独采用一种方式，也可以采用多种方式。至于什么情况下单独适用、什么情况下合并适用，需要根据案件具体情况并依据有关法律、司法解释的具体规定来确定，其最终目的是满足充分救济受害人的需求。本案中，原告在提出停止侵害、排除妨害、损害赔偿等请求时，还要求被告赔礼道歉，以满足原告人格尊严或者心理安慰的需求，但被告的侵占行为损害的是财产权利，并非人格利益，在原告提出的由被告承担其他民事责任承担方式得到支持的情况下，足以达到充分救济原告需求的目的，不符合适用赔礼道歉责任方式的条件。

编写人：湖南省湘阴县人民法院 陈肖思

六、其 他

66

共有产权保障住房的同住人 不适宜共同居住情形下的裁判思路

——蒋某某诉施某某等其他所有权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市第二中级人民法院(2023)沪02民终11496号民事判决书

2. 案由：其他所有权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):蒋某某

被告(被上诉人):施某某、王某、虞某某

【基本案情】

蒋某某与施某某原系再婚夫妻，双方于2008年登记结婚，2020年登记离婚。王某系施某某与其前夫之女，虞某某系王某丈夫。2014年蒋某某、施某某、王某、虞某某四人共同申请经济适用房。2016年6月，某房地产开发有限

公司、王某、某住房保障中心签订《上海市共有产权保障住房(经济适用住房)预售合同》，该合同附件《上海市共有产权保障住房使用协议》的当事人

为：某住房保障中心及共有产权保障住房（以下简称系争房屋）同住人施某某、蒋某某、虞某某。2018年王某登记为系争房屋权利人，产权证附记载明：合同载明的同住人：施某某、蒋某某、虞某某。蒋某某与施某某离婚后，施某某等人将门锁调换，蒋某某自2021年9月18日起一直在外租房居住。因施某某等人拒绝蒋某某居住系争房屋，故蒋某某起诉要求施某某等人对其居住权益予以补偿。

2022年，蒋某某曾向法院提起排除妨害纠纷诉讼，要求确认蒋某某在系争房屋中有居住权。法院认为蒋某某对系争房屋有居住的权利，但蒋某某与施某某已经离婚，蒋某某与施某某等就居住问题多次调解未果，矛盾较深，双方在系争房屋内共同居住生活与社会伦理常情不符，故对蒋某某要求王某、施某某、虞某某停止对蒋某某居住系争房屋的妨害，让蒋某某能在系争房屋内实际居住使用的诉讼请求不予支持。该案二审判决书中阐明“蒋某某就系争房屋的合法权益，可通过其他合法途径另行解决”。本案审理中，双方一致确认购买系争房屋首付款12万余元，贷款50万元，该贷款一直由王某、虞某某归还，剩余贷款也由王某、虞某某负担。蒋某某自2021年9月18日起在外租房居住。经评估，2023年3月8日为价值时点，系争房屋现状（带固定装修）状态市场价值为257.60万元，70%转让价款为180.30万元。

【案件焦点】

1. 蒋某某作为系争房屋的同住人，在其与施某某离婚后，是否能够继续居住、使用系争房屋；2. 如蒋某某不适宜在系争房屋内继续居住，其基本居住权益应当如何保障。

【法院裁判要旨】

上海市宝山区人民法院经审理认为：蒋某某作为系争房屋的同住人，对系争房屋享有居住等权利。蒋某某因客观情况无法在系争房屋内居住，无法对系争房屋行使权利，其要求获得补偿款，予以准许。考虑到蒋某某与王某、施某某、虞某某之间矛盾较深，保留蒋某某在系争房屋内的部分权利不利于系争房

屋的使用、处分，也容易导致蒋某某与王某、施某某、虞某某之间再起纷争，故本案中法院对蒋某某在系争房屋中的所有权利一次性处理完毕。考虑王某、施某某、虞某某对系争房屋享有的权利未进行分割，法院确定蒋某某对系争房屋享有的所有权利归王某、施某某、虞某某所有，王某、施某某、虞某某支付蒋某某补偿款。蒋某某提交的证据能形成证据链，证明其将动迁款10万元用于支付系争房屋首付款。且，蒋某某系经济适用房的共同申请人，应认定蒋某某系为自己对系争房屋享有的权利而出资。王某虽然提交部分装修出资凭证，但尚不足以证明全部装修费用均由王某出资，而蒋某某未提交证据证明其支付了装修费用，法院根据双方的举证情况酌情分配装修利益。综上，考虑蒋某某对系争房屋的贡献，在剩余贷款由王某、虞某某负担的基础上，法院酌情确定蒋某某对系争房屋享有的所有权利归王某、施某某、虞某某所有，王某、施某某、虞某某支付蒋某某补偿款35万元，蒋某某配合王某、施某某、虞某某办理同住人变更登记手续。

关于房屋租金，作为系争房屋的同住人，蒋某某有权在系争房屋内居住，现因双方矛盾较深等原因导致蒋某某未能在系争房屋内居住，蒋某某主张其未能居住期间的房屋租金，予以准许。但本案对蒋某某的权利进行补偿之后蒋某某不再对系争房屋享有居住的权利，故法院确认租金支付至本案判决生效之日止。根据王某、施某某、虞某某的陈述，蒋某某在2021年9月18日之前已经搬离了系争房屋，蒋某某主张租金自2021年9月18日起计算，予以准许。关于租金标准，法院参照系争房屋类似房屋的租金价格酌情确定。

上海市宝山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第三条规定，判决如下：

一、原告蒋某某对系争房屋享有的所有权利归被告王某、施某某、虞某某所有，被告王某、施某某、虞某某于本判决生效之日起十日内支付原告蒋某某补偿款35万元，原告蒋某某于本判决生效之日起十日内配合被告王某、施某某、虞某某办理同住人变更登记手续；

二、被告王某、施某某、虞某某于本判决生效之日起十日内按每月800

元的标准支付原告蒋某某自2021年9月18日起至本判决生效之日止的房屋租金；

三、对原告蒋某某的其余诉讼请求不予支持。

蒋某某不服一审判决，提起上诉。

上海市第二中级人民法院经审理同意一审裁判意见。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

住房问题是重大民生问题，关系着千家万户的基本生活保障。开始住房制度改革以来，具有中国特色的住房保障体系逐步形成。我国共有产权保障制度尚处于发展阶段，在审判实践中，共有产权保障住房在申请资格认定、分割、转让、继承、赠与、回购等多个环节纠纷频发，在目前制度规定尚不完善，法律法规未及时跟进的情况下，人民法院审判工作面临很大挑战。

一、共有产权保障住房制度的价值功能

上海市经济适用房制度选择采取共有产权模式，即保障性住房的产权由政府与购房人按份共有，在共有产权模式下，政府既是制度实施与秩序维护的管理者，又是房屋的按份共有人，除了公法上的权力还享有诸多民事权利，一旦购房者违规出租、出售房屋等情形出现，政府住房保障部门亦可诉诸私法救济。

共有产权保障住房制度在满足基本住房需求和充分利用市场机制方面，取得了显著的政策成效，具有很强的现实和社会意义。首先，上海市作为我国的金融中心，高价商品房较多，中低价位房源短缺，共有产权制度的实施使得中低收入人群能够以低于市场价的价格购入房屋，有效填补商品房住房空缺的同时又满足了中低收入人群的住房需求。其次，上海市共有产权住房的定价以“保本微利”为原则，综合考虑各方面因素进行确定，整体上能够平衡开发成本，减少政府财政压力，与过去的经济适用住房大规模资金投入相比，其优势不言而喻。此外，政府作为共有产权制度的设计者与实施者，在选择开发用地

时会综合考量各种影响因素，利用住房规划将中心城区人口向郊区引流，既缓解了中心城区的压力，又带动了周边郊区的发展。

二、共有产权保障住房制度中各方当事人的法律关系

共有产权保障住房制度对购房人和同住人的身份作出明确区分，在以家庭为单位申请共有产权保障住房时，家庭成员作为共同申请人，此时，全体申请人需要通过书面协商方式确定购房人，作为该房屋产权份额的共同共有人，其余申请人为同住人，若申请人之间无法就购房人达成一致意见，则全体申请人同为购房人。

同住人不享有共有产权保障住房的所有权，其对房屋享有的权能理应次于购房人。共有产权保障住房的个人产权份额在继承人符合共有产权保障住房申请条件的前提下可以发生继承，若继承人不符合条件，则按照共有物的法定分割方式予以处理。然而，在同住人死亡的情况下，共有产权保障住房不发生继承。

同住人对共有产权保障住房享有居住利益，且该居住利益要比居住权人享有的权能更丰富。首先，对于客观不再有居住需求的共有产权保障住房的腾退，将同住人的住房需求也考虑在内，只要同住人对共有产权保障住房还有居住需求，就不得要求其腾退房屋；其次，取得共有产权保障住房的房产证满5年后，同住人和购买人同等地享有购买政府产权份额的权利，且全体购房人和同住人应当就购买意愿、购房人等事项达成一致意见；最后，共有产权保障住房的上市转让，需经全体购房人、同住人一致同意。故而，在同住人之间共同居住的基础关系破裂，客观上无法继续共同居住时，应当给予丧失居住权益的同住人必要的经济补偿。

三、共有产权保障住房同住人不适宜继续共同居住情形下的裁判思路

共有产权保障住房的所有同住人对共有产权保障住房均合法地享有居住权益。例如，因离婚等客观原因导致情势变更，同住人不适宜继续共同居住在房屋内，如何在保障同住人基本居住权益的前提下，妥善处理好双方的矛盾系法院需要解决的关键难题。

1. 对于不适宜继续共同居住的同住人之间的纠纷，保留各同住人对房屋的居住权益不利于房屋的实际使用、处分，也容易导致各同住人之间再起纷争，故对一方同住人在保障房内的所有权利一次性处理完毕，方能有效地消除同住人之间纷争的根源。本案中，考虑到系争房屋的同住人蒋某某与施某某等矛盾较深，保留其在房屋内的部分权利不利于房屋的使用、处分，也容易导致其与施某某等再起纷争，故对蒋某某在系争房屋中的所有权利一次性处理完毕。

2. 由共有产权保障住房的购买人或实际占有使用房屋的一方同住人继续占有使用共有产权保障住房，未实际占有使用房屋的同住人一方搬离，并由占有使用一方支付搬离一方合理的补偿金，方能合理解决各同住人的居住权益保障问题。本案中，考虑施某某等对系争房屋享有的权利未进行分割，法院确定蒋某某对系争房屋享有的所有权归施某某等所有，施某某等支付蒋某某补偿款。

3. 关于补偿金的确定，应当从案件实际情况出发，结合当事人举证，综合考虑各方当事人对房屋的贡献、剩余贷款归还情况及房屋价值等，方能合理解决同住人的居住权益保障问题。本案中，考虑蒋某某对房屋的贡献，在剩余贷款由王某、虞某某负担的基础上，法院酌情确定蒋某某对系争房屋享有的所有权归施某某等所有，施某某等支付蒋某某补偿款35万元。

该案关于共有产权保障住房同住人之间就保障性住房居住权益发生冲突时的审判思路和解决方案，从案件实际情况出发，综合考量各方当事人的居住权益保障，合情合理，对于同类涉民生案件的审判具有一定的参考意义。

编写人：上海市宝山区人民法院 杨丽

名为典当实为民间借贷的司法认定

——海南某典当有限责任公司诉符某某、陈某某典当案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

海南省文昌市人民法院(2023)琼9005民初954号民事判决书

2. 案由：典当纠纷

3. 当事人

原告：海南某典当有限责任公司(以下简称某公司)

被告：符某某、陈某某

【基本案情】

某公司的经营范围包括动产质押、财产权利质押、房地产抵押等典当业务；2016年8月取得《特种行业许可证》；2021年5月取得《典当经营许可证》。

符某某、陈某某系夫妻关系，2020年6月，二人与某公司签订《房地产抵押借款合同》及补充协议，约定某公司向符某某、陈某某共计出借110万元，月借款利息及综合服务费率3%，符某某、陈某某以其名下的A、B两套房产作为担保。2021年1月6日，符某某、陈某某向某公司出具《借据》，载明以其名下的房产C作为抵押物向某公司借款30万元，月借款利息及综合服务费率3%。就上述房屋双方没有办理抵押登记。符某某、陈某某实际收到借款1274000元，已偿还借款1018000元，以上借款期限届满后，由于符某某、陈某某没有全部偿还借款，某公司起诉至法院，要求符某某、陈某某偿还剩余借款本金、利息、综合服务费及违约金。某公司为本案诉讼支付律师费30000元。

【案件焦点】

原、被告之间属于典当关系还是民间借贷关系。

【法院裁判要旨】

海南省文昌市人民法院经审理认为：典当关系是指当户将其动产、财产权利作为当物质押或者将其房地产作为当物抵押给典当行，交付一定比例费用，取得当金，并在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的行为。民间借贷关系是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。本案中，双方签订《房地产抵押借款协议书》《借款补充协议》《补充协议》《借据》时，原告尚未取得《典当经营许可证》，无典当经营资格。2022年3月22日，原、被告签订《房地产抵押借款补充协议书》时，虽然原告取得典当经营资格，但双方没有约定抵押物的赎回，原告也没有出具典票及将抵押物进行抵押登记，双方所建立的关系不具有典当关系的特征，而是具有一般民间借贷关系特征。故，原、被告所建立的不是典当关系，而是一般的民间借贷关系。本案案由应变更为民间借贷纠纷。

原、被告之间建立的是民间借贷关系，故应适用民间借贷相关法律调整。根据《中华人民共和国民法典》第三百九十五条、第四百零二条的规定，以房地产作为抵押物应当办理抵押登记，本案中被告提供抵押的房屋并未办理抵押登记，故案涉《房地产抵押借款协议书》《借款补充协议》《补充协议》《房地产抵押借款补充协议书》所涉房屋抵押不成立。以上合同及双方签订的《借据》中涉借贷部分约定的利息和综合费用为月利息3%，折合年利率36%，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条“出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但是总计超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的部分，人民法院不予支持”的规定，原告主张利息、综合费用超出一年期贷款市场报价利率四倍部分属于无效，不予支持。上述合同关于借款其他部分的约定是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规规定，合法有效，对双方当事人具有约束力。本案

借款本金应确定为1274000元，双方约定的还款期限已届满，原告主张被告偿还借款本息，予以支持。双方没有约定逾期利息，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十八条第二款第二项“约定了借期内利率但是未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持”的规定，逾期利息按借款合同成立时一年期市场报价利率四倍支付。

本案纠纷因被告未按合同约定履行还款义务引起，根据双方的约定、争议标的额和海南省律师服务收费标准，原告主张律师费30000元，予以支持。

海南省文昌市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第三百九十五条、第四百零二条、第五百零二条第二款、第五百零九条第一款，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条、第二十八条第二款第二项、第二十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：

一、被告符某某、陈某某于本判决生效之日起十日内偿还418419.44元借款本金及相应利息（其中以178419.44元为基数从2022年6月8日起至付清该款之日止、以240000元为基数从2021年3月4日起至付清该款之日止，按照年利率15.4%计算）给原告某公司；

二、被告符某某、陈某某于本判决生效之日起十日内向原告海南某典当公司支付律师费30000元；

三、驳回原告某公司的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决现已生效。

【法官后语】

本案争议核心在于厘清典当关系与民间借贷关系的法律边界。在民间借贷利率严格受限的背景下，部分当事人试图以“典当”之名行“借贷”之实，通过设计高额综合费用、模糊交易流程等方式规避利率监管。此类行为不仅会扰乱金融市场秩序，更可能加重借款人负担。因此，准确识别法律关系性质，需从典当法律关系的构成要件出发，结合司法实践中的区分要点与实质审查标准，

穿透合同表象探究交易本质。

一、典当法律关系的构成要件解析

典当法律关系的成立需同时满足主体、客体与行为三要素，三者缺一不可。

一是主体资质的法定性。根据《典当管理办法》，典当行必须取得商务部核发的《典当经营许可证》，并完成工商登记后方可开展业务。本案中，原告在签订《房地产抵押借款协议书》《借据》等文件时尚未取得经营资质，即便后续补正，亦无法改变前期行为的违法性，直接否定了典当关系成立的基础。这一要件的设置，本质上是为了维护金融市场准入秩序，防止无资质主体通过“伪典当”形式规避监管。

二是客体流转的特殊性。典当交易以当物的质押或抵押为前提，其中动产需完成交付占有，不动产或财产权利需依法登记。本案中，双方虽约定以A、B、C三套房产作为抵押物，但均未办理抵押登记，根据《中华人民共和国民法典》第四百零二条规定，抵押权未依法设立；同时，合同未体现动产质押中的交付环节，导致担保物权无法有效成立，不符合典当关系中“以物担保”的核心特征。这种对客体流转的严格要求，旨在保障典当行的优先受偿权，与民间借贷中相对灵活的担保方式显然不同。

三是行为流程的规范性。典当交易需遵循“当金交付—典票出具—回赎约定”的完整流程。典票作为法定凭证，需载明当户信息、当物详情、估价金额、费率等关键要素；回赎条款则明确当户偿还当金、赎回当物的权利与期限。而本案中，原告始终未出具典票，且合同未约定回赎条件及绝当程序，不具备典当关系成立的形式与实质要件。从法律逻辑上看，典票不仅是交易凭证，更是典当双方权利义务的书面对确认，缺失典票将导致交易无法纳入典当法律规制体系。

二、典当与民间借贷区分认定的核心要点

司法实践中，区分两种法律关系需摒弃“以名定性”思维，应从费用结构、担保实现与合同目的等维度进行实质审查。

第一，费用性质与标准差异。典当关系中，当户需支付利息与综合费用，其中综合费用是典当行提供估值、保管等服务的对价，其上限由《典当管理办

法》明确规定(如房地产抵押典当的月综合费率不得超过27%)。而民间借贷中,出借人仅能收取符合法律规定的利息及必要费用。本案约定的“月借款利息及综合服务费率3%”,即年化36%,远超民间借贷利率司法保护上限,且未区分费用性质,实质是将高额利息包装为“综合服务费”,以规避民间借贷利率限制(本案适用起诉时一年期 LPR 的4倍,即15.4%)。这种费用混同的设计,本质上是利用典当与借贷的制度差异进行套利,严重损害借款人利益。

第二,担保物权实现路径不同。典当行可通过“绝当”程序直接处置当物以实现债权;而民间借贷的担保物权需依据《中华人民共和国民法典》规定,通过诉讼或非诉程序行使抵押权、质权。本案未约定绝当条款,且抵押未登记,导致担保物权无法有效设立,更符合民间借贷中未完善担保手续的特征。值得注意的是,绝当制度是典当关系的重要标志,其赋予典当行快速变现当物的权利,而民间借贷的担保实现则更强调程序正义,二者在风险处置效率上存在显著差异。

第三,合同目的与风险分配逻辑不同。典当行通过占有当物控制风险,其收益依赖综合费用与当物变现;民间借贷则以借款人信用为基础,风险主要通过利息补偿。本案中,双方既未转移“当物”占有,也未建立规范的“当物”处置流程,表明交易实质仍为资金借贷,而非典当。从经济关系来看,典当更类似于“以物融资”,而民间借贷则是“以信融资”,这种本质区别决定了二者在法律适用与责任承担上的不同。

三、典当关系成立与否的实质审查方法

法院在区分认定典当与借贷时,需遵循“穿透式审查”原则,结合法律规定与交易实质综合判断。

第一,资质与程序的合规性审查。首先,核查典当行经营资质,对无资质或超范围经营行为直接否定典当关系;其次,审查典票、登记、交付等形式要件,缺失任一环节均可能导致典当关系不成立。司法实践中,部分主体试图通过“事后补证”方式挽救无效典当,但根据《中华人民共和国民法典》第一百五十三条规定,违反强制性规定的民事法律行为自始无效,补正行为无法溯及既往。

第二，权利义务的实质比对。重点分析费用构成、担保实现方式及合同履行内容。若费用远超法定标准、担保物权未依法设立，或未体现典当特有的回赎、绝当机制，则倾向于认定为民间借贷。例如本案中，双方约定的高额综合服务费不仅违反《典当管理办法》，更突破了民间借贷的司法保护利率红线，这一细节成为认定法律关系性质的关键事实。

第三，交易目的与市场秩序考量。对以典当之名规避利率限制、加重借款人负担的行为，法院应依据《中华人民共和国民法典》公平原则及金融监管政策，否定其合同效力或调整费用标准。从司法政策导向来看，最高人民法院多次强调对“套路贷”“高利贷”的打击，本案将综合服务费纳入民间借贷利率规制，正是落实这一政策的具体体现。此外，准确区分典当与借贷，还有助于维护典当行业的健康发展。

本案裁判彰显了司法对金融创新的审慎态度，在尊重当事人意思自治的同时，通过准确识别法律关系性质，平衡各方利益，规范民间融资行为，为同类案件审理提供了参考。未来，随着金融交易模式的不断创新，司法机关需持续加强对“名实不符”交易的穿透式审查，在保障金融活力的同时，筑牢风险防范的法治屏障。

编写人：海南省文昌市人民法院 王秋雅